

Aun más tardío es el procedimiento *per libellos*, dominante en la época de Justiniano. Toma su nombre de los documentos (*libelli conventionis y contradictionis*) en los que actor y demandado declaran las recíprocas pretensiones y defensas. También el *libellus conventionis* lo redacta el actor o persona de su confianza; la misión de transmitirlo al demandado y de intimar a éste a adherirse a la solicitud del actor o redactar el *libellus contradictionis* corresponde a un *exsecutor negotii*, que es normalmente un agente subalterno del magistrado³⁴.

Parece que también en el derecho justiniano deba indicarse el nombre de la acción que el actor entiende ejercer³⁵; pero tal indicación, que conservaría el antiguo nombre de *editio actionis*, habría perdido en todo caso el valor que derivaba de la correspondencia entre la *formula* edictal y el *iudicium* sobre el cual las partes entablaban la *litis*. La indicación de la acción sirve ahora sólo para determinar aproximadamente la relación controvertida y para facilitar al juez la consulta de las obras doctrinales; pero las acciones particulares no están más delimitadas según los términos que para cada una estaban señalados por las palabras de la fórmula, sino con relación a una *natura actionis*, que expresa su fundamento material y su dirección práctica³⁶.

También el nombre de la *litis contestatio* se conserva, merced a la habitual *reverentia* hacia las *antiquitas*, en el *Corpus iuris* y en las fuentes bizantinas; pero con las características formales que la *l. c.* tenía en el procedimiento formulario (p. 153), ha desaparecido también el efecto de consunción y novación de la relación deducida en un juicio, mientras otros efectos importantes (por ejemplo, la interrupción de la prescripción) se retrotraen al momento de la entrega del libelo. Se instruye ahora la *litis contestatio* al principio de la audiencia, en el momento en que el

³⁴ Véase COLLINET, *La procédure par libelle*, París, 1932.

³⁵ Según BAUGI (*Scritti per il centenario della nascita di M. Amari*, Palermo, 1910, II, ps. 284 y ss.), el nombre tendría que estar indicado en el libelo; según COLLINET (*op. cit.*, ps. 116 y ss.), correspondería al *exsecutor negotii*, en el acto de la entrega del libelo, la tarea de mostrar al demandado, sobre un prontuario preparado con este fin, el nombre de la acción que se intenta.

³⁶ Cfr. LONGO, *Il criterio giustiniano della natura actionis*, en *Studi Scialoja* (1904), I, ps. 607 y ss. Quien quiera tener una idea de la multiplicidad de problemas jurídicos que en la época posclásica podía presentarse en el ámbito de una sola *litis*, puede consultar los dos rescriptos del siglo V, editados por MOMMSEN, *Scritti giur.*, 2, ps. 342 y ss.

actor refiere personalmente y de viva voz los hechos que han dado lugar a la causa (*narratio*); aparte de la tendencia arcaizante de Justiniano, que ha querido hacer lugar en su derecho a una institución tan a menudo mencionada en las fuentes clásicas, la nueva *l. c.* sirve como punto de partida de varios términos, como el de los tres años después de los cuales se considera perimida la instancia.

Se borra también la contraposición entre *actio* y *exceptio*. Ella derivaba, fuera y más que de la estructura de la fórmula, de la oposición entre los varios sistemas de que estaba constituido el derecho antiguo y clásico; puesto que en la época posclásica tal oposición se siente menos, es natural que para los justinianeos no deba existir mucha diferencia entre considerar una acción como *ipso iure* infundada o como paralizada por una excepción. Sin embargo, la *exceptio* subsiste como concepto procesal, para indicar las circunstancias que quitan eficacia a la acción sólo si se hacen valer a su debido tiempo por el demandado; tal la excepción de incompetencia relativa y las que defienden contra los efectos de un negocio jurídico viciado (*exc. doli, metus, etc.*).

*

* *

A la exposición de los principios fundamentales del proceso posclásico agregaremos algunas noticias, que por razones de brevedad circunscribimos a la época de Justiniano³⁷.

El ordenamiento judicial se confunde ahora con la jerarquía administrativa. La justicia no es administrada, ni aun por vía de apelación, por el emperador mismo, aunque siempre se lo haga en su nombre. En Constantinopla es juez supremo el *praefectus urbi*, y para las causas de menor cuantía (o para cualquier causa por delegación suya) su *vicarius*; a su lado tienen una competencia más o menos limitada el *praefectus annonae* y el *praefectus vigilum*, y para las causas fiscales los dos *rationales* (*sacrarum largitionum* y *rei privatae*). En las provincias es *iudex ordinarius* el presidente, pero las *causae minores* son de competencia del *de-*

³⁷ Noticias mucho más copiosas véanse en CHECCHINI, *Studi sull'ordin. proc. romano e germanico*, I, *Il proc. romano*, Padova, 1925; y en COLLINET. *op. cit.*

fensor plebis o *civitatis*, transformado en magistrado judicial de su función originaria de tutor de los intereses del bajo pueblo contra los *potentiores*. De las sentencias del *defensor* se apela ante el presidente, de las del presidente o del *vicarius* ante el *praefectus urbi*; cuando éste haya pronunciado sentencia en primera instancia se admite, en lugar de la apelación, una *supplicatio*, como consecuencia de la cual él mismo confirma la primera sentencia o la reforma.

El juicio, precedido por los *libelli conventionis* y *contradictionis* y por el cambio que de ellos se efectúa por conducto del *exsecutor*, se inicia, normalmente, con la comparecencia ante el juez el día señalado por el actor, o mejor con la exposición que el actor hace de los hechos (*narratio*) y con las objeciones del demandado (*contradictio*); después ambas partes prestan el *iusiurandum de calumnia*, es decir, juran haber intentado la acción, o quererla resistir, con la plena persuasión de la bondad de su derecho y no con maldicia (*calumnia*, correspondiente al francés *chicane*). Después de las declaraciones de los abogados, que precisan los puntos de vista de las partes, una sentencia del juez las admite, si es del caso, a probar sus afirmaciones. La estimación de las pruebas, que los clásicos dejaban librada a la conciencia del juez, está ahora sujeta a una serie de reglas: la prueba escrita (*fides instrumentorum*) prevalece sobre la testimonial; el testimonio de uno solo, aunque sea senador, no prueba; los testigos de clase más elevada (*honestiores*) prevalecen sobre los *humiliores*, a los que se les impone el juramento; el juez puede requerir el dictamen de peritos calígrafos, agrónomos, médicos, etc. Al lado de las pruebas, se reconoce para varias hipótesis el valor de las *praesumptiones*, deducciones obligadas de hechos conocidos a desconocidos, y válidas, por virtud de la ley, hasta la prueba contraria (*pr. iuris tantum*) o también con exclusión de toda prueba contraria (*pr. iuris et de iure*). Agotadas las pruebas y formada la convicción del juez, éste debe redactar la sentencia por escrito y leerla en voz alta, en presencia de sus subalternos y de las partes; sin embargo, el pronunciamiento es válido aunque las partes, debidamente invitadas, no asistan. La sentencia puede ser de absolución o de condena; pero la condena no es más, como en el derecho clásico, necesariamente pecuniaria, sino que tiene el mismo objeto de la obligación primaria no cumplida: por ejemplo, la transferencia de la propiedad si se ha hecho valer en juicio

una obligación *in dando*, o la restitución de la cosa por parte del poseedor injusto si se ha intentado una *rei vindicatio*. El vencido está obligado a resarcir los gastos judiciales de la contraparte; gastos que por las crecientes pretensiones de los patrocinantes y por las compensaciones debidas al personal subalterno de los tribunales, como así también por la abundancia de actos escritos, se han vuelto exorbitantes, de mínimos que eran en la edad clásica³⁸.

Las sentencias son normalmente apelables; pero la intención de apelar debe ser declarada inmediatamente, y los *libelli appellatorii* deben hacerse llegar al juez de primera instancia en un término brevísimo, que las Novelas de Justiniano fijan en diez días; el juez de primera instancia los trasmite al de apelación junto con las actas de la causa y con una relación (*litterae* o *libelli dimissorii*, o ἀποστολοί). Ante el juez de apelación se procede *ex novo*, y pueden ofrecerse nuevas pruebas; pero la ventaja que de ello puede derivar para el apelante está más que compensada por el peligro de una agravación de la primera sentencia, y por las penas pecuniarias establecidas contra los apelantes temerarios.

Después de la condena en apelación, o después que el demandado condenado en primera instancia haya dejado trascurrir los términos para apelar, la condena debe ser cumplida. Cuando esto no ocurra por espontánea prestación, se puede recurrir a uno entre los siguientes medios:

α) aprehensión de la cosa propia del vencedor, o de la que le debe el vencido, en presencia de los *apparitores* del magistrado y con el eventual concurso de la fuerza pública;

β) *pignus ex causa iudicati captum*, consistente en la aprehensión de una o varias cosas determinadas, con los mismos concursos y garantías, por parte del destinatario de una condena al pago de una suma de dinero: las cosas aprehendidas de esta manera se venden en subasta y la parte del precio que excede el monto de la condena se restituye al deudor;

γ) en la hipótesis de que sean varios los acreedores, *missio in bona rei servandae causa*, y sucesivamente *distractio bonorum* (no más venta en bloque) (cfr. ps. 162 y 164); de este procedimiento puede liberarse el deudor, mediante la cesión volun-

³⁸ Sobre el tema, cfr. CHIOVENDA, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 7, 1894, ps. 275 y ss.; y *La condanna nell' spese giudiziali*, 1901, ps. 2 y ss.

taria de los bienes, cuando haya quedado reducido a la insolvencia sin su culpa (p. 164).

*
* *

Se ha visto ya (ps. 153 y ss.) cómo la estructura privatista del proceso formulario excluía la posibilidad de que la *litis contestatio* tuviese lugar en ausencia de una de las partes; si el que había prestado un *vadimonium* para la comparecencia *in iure* no se presentaba, tenía lugar el procedimiento ejecutivo, pero la regla debe entenderse como una sanción de la obligación procesal incumplida, no como equiparación de la contumacia a la pérdida del proceso. En cambio, como consecuencia de la obligación procesal asumida mediante la *litis contestatio*, la ausencia injustificada *apud iudicem* tenía como sanción la pérdida de la *litis*, sin que el adversario estuviese obligado a producir pruebas. En el sistema de la *cognitio extra ordinem* desaparecen estos principios, y mientras por un lado se admite que un proceso pueda desarrollarse desde el principio hasta el fin en ausencia (*contumacia*) de una de las partes, se dejan a salvo también los derechos del ausente, obligando a la parte que compareció a probar el fundamento de sus pretensiones o defensas.

En verdad, esto fué admitido al principio solamente respecto del demandado, reduciendo en estos límites la obligación de comparecer que sobre él pesaba en el derecho clásico (p. 153). La eventualidad de un proceso sin contradictor fué, por lo demás, evitada con todo cuidado; ya en el período de la *litis denuntiatio* se requería, antes de declarar la contumacia (*δίκη ἔρημος* de los papiros), una triple denuncia, en la última de las cuales la autoridad judicial se sustituía al actor para ordenar la comparecencia (*denuntiatio ex auctoritate, παραγγελία ἐξ αὐθεντίας*), y en la época justiniana se admitió que el demandado por una acción privada fuese llevado a juicio *manu militari* o mantenido en arresto, de modo que el proceso contumacial halló lugar prácticamente sólo a cargo de los que se ocultaban.

Respecto del actor, en cambio, el principio clásico de que la ausencia lleva consigo la extinción de la acción, permanece en vigor aun en el período de la *denuntiatio*, y el derecho del Código teodosiano se limitó a diferir esta sanción para cuando el actor

hubiese dejado de obedecer a dos sucesivas intimaciones del magistrado. Sólo el derecho justiniano equiparó a este respecto al actor con el demandado, creando también para el primero una obligación jurídica de comparecencia y admitiendo por lo demás que él pudiese también ganar la *litis*, si de las actas de la causa resultara demostrado su buen derecho³⁹.

*
* *

Algunas palabras sobre ciertos procedimientos especiales.

Desde la época clásica, sin que haya habido proceso o en curso de éste, una de las partes o el juez puede solicitar, respectivamente mediante una *supplicatio* o una *epistula*, la decisión del emperador. Ésta puede limitarse a la cuestión de derecho, dejando que el juez establezca si los hechos corresponden a las afirmaciones del postulante; pero puede también manifestarse en el sentido de que el emperador asume el conocimiento directo de la *litis* en su *auditorium*⁴⁰. Mientras en la edad posclásica desaparece el conocimiento directo del príncipe, la facultad de requerir la emisión de rescriptos fué sometida por Constantino y sus sucesores a reglas precisas, impidiendo en particular que se recurriera al emperador en las postrimerías de un proceso ante los jueces ordinarios y determinando minuciosamente el procedimiento a seguirse bajo la guía de *exsecutores* especiales, después que los interesados hubiesen obtenido un rescripto⁴¹.

³⁹ Cfr. STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren* [Estudios sobre el proceso contumacial romano], Monaco, 1914; y por último, ARU, *Il proc. civ. contum.*, Roma, 1934.

⁴⁰ Una inscripción relativa a un proceso desarrollado ante Caracalla (año 216) ha sido recientemente publicada por ROUSELL y por DE VISSCHER en la revista "Syria", 1942-1943, ps. 173 y ss.; se la ha publicado nuevamente con algunas anotaciones mías en el "Bull. Ist. Dir. Rom.", 49-50, 1947, ps. 46 y ss.

⁴¹ Los papiros bizantinos de El Cairo contienen, en efecto, numerosos ejemplos de procesos por rescripto: cfr. sobre ellos PARTSCH, *Scritti inediti e rari*, ps. 194 y ss., y el documento más característico (P. Cairo Masp. 67032) en mis *Negotia*, n° 179. Un caso más antiguo (2ª mitad del siglo V) creyó reconocer COLLINET ("Rev. Égyptologique", 2, 1921, ps. 70 y ss.) en el papiro publicado por MITTEIS para el jubileo Luhn, Leipzig, 1912; pero la cosa es muy incierta (cfr. la 1ª ed. de este *Manual*, y por último el mismo COLLINET, *Proc. par libelle*, p. 402).

Con el nombre de *summaria cognitio* (o con *summatim cognoscere*) se indica un proceso que prescinde de alguna parte de las normas sancionadas en garantía de los litigantes en el proceso ordinario: sea que se abrevien los términos legales de las distintas *denuntiationes* y de la presentación en juicio, sea que se simplifique la prueba, que se excluya la apelación, etc. Sumario es sobre todo, en esta época, el procedimiento que sustituye al antiguo procedimiento interdictal: mientras éste solía lograr rápidamente su fin por la obediencia voluntaria del destinatario a la intimación del magistrado, el derecho justiniano considera a los interdictos como una categoría de acciones, que se distingue por un especial carácter de provisionalidad y por la rapidez con que el juicio se desarrolla. En este campo y en otros, la terminología del *summatim cognoscere* es introducida por los justinianos en los textos clásicos recogidos en el Digesto⁴².

Hay que recordar, por último, la tendencia, manifestada desde el siglo IV en los concilios cristianos, a imponer a los sacerdotes la obligación de elegir como árbitro de sus controversias al obispo; tendencia ante la cual la legislación imperial se manifestó al principio indiferente, considerando al obispo a la par de cualquier otro árbitro libremente elegido por las partes, pero que después reconoció dentro de ciertos límites, dando lugar a una verdadera jurisdicción episcopal en las controversias promovidas contra eclesiásticos⁴³. La *episcopalis audientia* concurrió por último con la jurisdicción civil también en las controversias entre laicos, y a los obispos se les reconoció también la facultad de interponerse a fin de que los desheredados de la fortuna encontraran ante los tribunales comunes suficiente tutela.

§ 4. LA COSA JUZGADA Y EL CONCURSO DE LAS ACCIONES

El principio *bis de eadem re ne sit actio*, ya probablemente afirmado desde la época de las *legis actiones* (p. 127), se aplica

⁴² BIONDI, *Summatim cognoscere*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 30, 1921, ps. 220 y ss.; H. KRUEGER, *Il s. c. e il diritto classico*, en "Rev. Fund. Savigny", 45, 1925, ps. 39 y ss.

⁴³ Sobre el desenvolvimiento histórico (muy controvertido), cfr. DE FRANCISCI, *Per la storia dell'episcopalis audientia*, en "Annali Univ. Perugia", 30, 1919, ps. 191 y ss.

en el derecho clásico en dos formas diversas: en los *iudicia legitima in personam*, haciendo caducar lisa y llanamente la acción para quien ya una vez haya deducido en juicio la relación litigiosa, con el efecto de que el juez que de cualquier manera llegue a conocer el proceso precedente deba rechazar la demanda renovada; en las acciones *in rem* y en los *iudicia quae imperio continentur*, atribuyendo al demandado una *exceptio* especial para el caso. Esta excepción lleva comúnmente en las fuentes el nombre de *exceptio rei iudicatae*, en consideración al hecho de que en la gran mayoría de los casos el proceso precedentemente intentado ha sido llevado hasta la sentencia; pero su nombre completo es *exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae*⁴⁴, siendo para los efectos bajo examen, completamente indiferente que una sentencia haya sido pronunciada o no, pues la exclusión de toda acción sucesiva deriva de la *litis contestatio* producida.

Es condición de esta eficacia exclusiva de la *litis contestatio*, como se deduce de la vieja máxima y del nombre de la excepción clásica, la *eadem res*, es decir, la identidad entre la relación otra vez disputada y la que es objeto de la acción sucesiva⁴⁵. La *eadem res* es evidente cuando, sobre la base de iguales presupuestos de derecho y de hecho, el mismo actor solicita nuevamente la misma fórmula contra el mismo demandado: tal, si quiero intentar nuevamente contra Ticio a quien considero mi deudor por mutuo, la *actio certae creditae pecuniae* ya intentada otra vez, o si, reivindicada una cosa contra Sempronio —poseedor—, la reivindico nuevamente en su contra, sobre la base de la misma supuesta causa de adquisición. Pero la *eadem res* es a menudo reconocible también fuera de esta hipótesis extrema, cuando relaciones jurídicas aparentemente distintas en las personas o en el objeto sean sustancialmente identificables.

Ante todo en el aspecto subjetivo. No sólo si una relación ha sido deducida en juicio por el causante, el heredero queda vinculado como si la *contestatio* fuese suya, sino que también si después de la primera *contestatio litis*, otro ha adquirido, en la parte bajo causa, la propiedad de la cosa litigiosa o un derecho

⁴⁴ Tradúzcase: "excepción de controversia juzgada o trasfundida en la fórmula".

⁴⁵ Es probable que precisamente para afirmar la exclusión de toda acción futura se comprendiesen en la fórmula *in personam* las palabras *qua de re agitur* (cfr. en p. 140 el primero y el cuarto ejemplo).

(por ej., de prenda) sobre ella, la *exceptio* vale en favor y en contra del adquirente. Igualmente, en las obligaciones correales, que crean una relación de interdependencia entre todos los coacreedores o codeudores, la *litis contestatio* cumplida entre un acreedor y un deudor impide, cualquiera sea el resultado práctico del proceso, que la acción sea nuevamente intentada por otros o contra otros. A reglas particulares dan lugar también las hipótesis, ya recordadas en la p. 38, en las que una relación jurídica fundamental (por ejemplo, la filiación legítima, o la pertenencia de una servidumbre a un fundo) es presupuesto de ulteriores relaciones entre las mismas o distintas personas; en casos semejantes, la verificación realizada en una sentencia dictada entre los legítimos contradictores de la relación fundamental (padre e hijo, propietarios del fundo sirviente y del dominante) repercute sobre las controversias en torno a las relaciones que de ella dependen⁴⁶.

Pero tampoco desde un punto de vista objetivo el *bis de eadem re agere* se resuelve siempre en el hecho de solicitar varias veces la misma fórmula, pues la jurisprudencia romana reconoce a menudo la *eadem res* en el sucesivo ejercicio de acciones diversas, cuando se fundan en los mismos presupuestos y tienden al mismo resultado práctico. Este fenómeno se expresa diciendo que las acciones *concurrunt*; y nuestras fuentes nos dicen que "*si quae earum actum fuerit, aliae tolluntur*" (D. 13, 6, 18 § 1), o más técnicamente afirman "*altera electa alteram consumi*" (D. 44, 7, 34 pr.).

Sin embargo, el problema práctico acerca de las veces en que aquellos dos requisitos (de la identidad de presupuesto y de resultado) subsisten y de las veces en que faltan, se halla entre los más tormentosos de nuestra ciencia⁴⁷; y no sólo por las múltiples interpolaciones que superponen en esta parte más que en otras,

⁴⁶ Debo necesariamente limitarme a pocos paradigmas. Sobre el tema véase la sólida investigación de BETTI, D. 42, 1, 63: *Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in dir. rom.*, Macerata, 1922.

⁴⁷ Entre los estudios sobre el tema, está todavía hoy fresquisimo el de nuestro gran ALIBRANDI, *Del concorso delle azioni* (1870), publicado nuevamente en *Opere*, ps. 163 y ss. Una revisión completa de las fuentes ha sido emprendida por LEVY en la obra sobre *Die Konkurrenz der Aktionen und Personen* [Concurso de acciones y de personas], de la cual se han publicado el vol. 1º (Berlín, 1918) y la primera parte del 2º (1922). Cfr. también NABER, *De concurrentibus actionibus* [Obs. cxxi], en "*Mnemosyne*", 52, 1924, ps. 250 y ss.; 53, 1925, ps. 10 y ss. y 225 y ss.

el pensamiento justinianeo al clásico, de manera que resulten difícilmente reconocibles tanto uno como otro, sino también porque, en el mismo ambiente de la jurisprudencia clásica, el juicio sobre la identidad o diversidad entre los presupuestos de dos distintas acciones importaba un minucioso análisis de los varios elementos de la especie concreta, y sobre este análisis no podían dejar de influir las diversas tendencias científicas y preocupaciones prácticas de cada uno de los juristas.

De todos modos, puede afirmarse con seguridad una tendencia general a aplicar el principio "*altera electa alteram consumi*" a todas las acciones que tuvieran por fin conservar —en determinada situación práctica— la integridad patrimonial, recuperando lo que nos pertenece o se nos debe (acciones que GAYO designa como aquellas *quibus rem persequimur*, y que la ciencia llama reipersecutorias; así el heredero, que puede dirigirse siempre contra el poseedor de una cosa hereditaria con la acción de propiedad (*rei vindicatio*) y a veces también con la de herencia (*hereditatis petitio*), debe contentarse con una sola; y análogamente el comprador que haya descubierto en la cosa adquirida un vicio, mientras tiene la elección entre la acción *redhibitoria* (para la restitución del precio íntegro) y la *aestimatoria* (para su reducción), al intentar una de esas acciones extingue la otra.

En cambio, en materia de acciones penales, ya se hallen en concurso entre sí o con acciones reipersecutorias, prevalece el principio de la acumulación: la víctima del hurto puede intentar la *condictio ex causa furtiva* para la recuperación de la cosa y la *actio furti* para la pena del *duplum* o *quadruplum*, sin que el ejercicio de una perjudique a la otra; el amo a quien alguien haya querido inferir injuria, maltratando a su esclavo, acumula la *actio legis Aquiliae* por el daño, con la *actio iniuriarum* por el ultraje. Pero hay también —según parece— hipótesis en las cuales la jurisprudencia, aun reconociendo técnicamente apropiado el principio de la acumulación, lo ha derogado por un camino indirecto, estableciendo la máxima de que el juez no debe pronunciar la *condemnatio* en que remata la acción primeramente intentada, sino cuando el actor dé caución de no intentar la segunda, o que llamado a juicio con la segunda acción, el demandado, pueda oponer la *exceptio doli*: esto no siempre para excluir del todo la segunda acción, sino también para reducirla *a priori*, si

fuera el caso, del *duplum* al *simplum*, o del *quadruplum* al *triplum*⁴⁸.

Las reglas en vigor en el derecho clásico sobre la cosa juzgada, fueron derogadas en el justiniano de distinta manera; pero todas las desviaciones se pueden reducir a la tendencia a que el actor obtenga de todos modos la satisfacción de su pretensión, y a que nunca tenga más de lo que corresponde a una estimación completa y equitativa del caso ocurrido. De ahí ante todo la consecuencia de que la eventual consunción de la segunda acción, no derive más del hecho de haberse cumplido sobre la primera la *litis contestatio*, sino de la condena pronunciada y cumplida. En otro lugar (cap. XIX, § 4) se verá cuáles pueden ser las consecuencias derivadas del régimen de las obligaciones correales; aquí corresponde recordar que la excepción no se llamó ya *rei iudicatae vel in iudicium deductae*, sino simplemente *rei iudicatae*, y que aun este nombre fué entendido en un sentido del todo nuevo, cual es el de que esté prohibido al actor ejercer la segunda acción solamente si, a través del procedimiento ejecutivo que ha seguido a la primera, ha obtenido plena satisfacción. En cuanto a la acumulación de las acciones, el derecho justiniano se esfuerza por excluirla en muchas hipótesis; y cuando la admite, lo hace la mayoría de las veces extendiendo el principio de que el ejercicio de la segunda acción sirve para obtener únicamente la diferencia entre la ventaja pecuniaria que el actor habría obtenido ejerciéndola y la que ha obtenido de la primera; tal el caso, por ejemplo, en el recordado concurso de las acciones *legis Aquiliae* e *iniuriarum*. Más aún: JUSTINIANO hasta admite que en casos semejantes el juez de la primera acción pueda ampliar la *condemnatio*, comprendiendo en ella lisa y llanamente lo que el actor podría tener de más si intentase la segunda. Soluciones facilitadas todas por la degeneración de las acciones en meras y aproximativas denominaciones del resultado económico a que tiende el actor (p. 170).

⁴⁸ Fuertemente discutida es, sin embargo, la determinación de las acciones en las cuales esta llamada "consunción judicial" tenía lugar; divergen sobre todo los puntos de vista de LEVY (op. cit., vol. II, parte 1ª) y de VOCI (*Risarcimento e pena privata*, Milano, 1939, ps. 121 y ss.).

LA PROPIEDAD Y LOS OTROS DERECHOS SOBRE LAS COSAS

CAPÍTULO V

LAS COSAS

Concepto de cosa: cosas corporales e incorporales. Las distinciones entre las cosas según sus características físicas y económicas y según su regulación jurídica.

Cosa es, en sentido propio, todo objeto del mundo exterior susceptible de goce por parte del hombre, sea que la naturaleza o la industria lo deslinde respecto a todo otro objeto, o que la limitación sea hecha o supuesta a los solos fines del derecho, en un ambiente continuo: las cosas muebles (por ejemplo, un caballo o una mesa) pertenecen a la primera categoría; los inmuebles por naturaleza (terrenos y casas), a la segunda. Para que un objeto sea cosa en el sentido del derecho, es necesario que sea útil, es decir, accesible y deseable; en consecuencia, se hallan fuera del concepto jurídico de cosa los metales existentes en la Luna, como también las infinitas plantas y animales de los que la industria humana no sabe extraer utilidad.

Ya hemos visto (p. 14) que GAYO, dando a las cosas ahora definidas el apelativo de *corporales* (*quae tangi possunt*), las distingue de las *incorporales* (*quae tangi non possunt*), y coloca en esta última categoría los derechos subjetivos, considerados como bienes, o sea como elementos del patrimonio. La distinción (que coincide, a grandes rasgos, con la que establecen los economistas entre bienes materiales e inmateriales) no es común a toda la jurisprudencia romana, pues la mayor parte de los juristas nunca hablan de cosas incorporales, y usan la expresión *res corporalis*

y el equivalente *corpus* en contraposición a las sumas o cantidades de cosas fungibles, como el dinero o los cereales¹. Los pocos pasajes no gayanos del Digesto, donde se alude a una distinción entre cosas corporales e incorporeales son, probablemente, interpolados². Más bien podría aproximarse la distinción gayana a la que CICERÓN (*Topica*, 5, 27) establece entre las cosas *quae sunt* y las *quae intelleguntur*.

Parece que GAYO hubiera sido el primero entre los juristas en adoptarla, mientras el modelo que él venía elaborando no la contemplaba; pero ciertamente ella deriva de la filosofía griega, que daba gran relieve a la distinción entre *σωματικά* y *ἀσώματα*. Y evidentemente satisfizo mucho a los bizantinos, quienes la refirieron a menudo en las leyes y en los documentos y la transmitieron a la ciencia medieval. Sólo en época reciente se ha producido una reacción, basada en la heterogeneidad (ya señalada en la p. 14) de los dos términos de la distinción.

No puede, sin embargo, negarse que en ciertos casos la objetivación (o hipostatización) de las relaciones jurídicas, y su consideración al modo de las cosas, sea técnicamente útil a la jurisprudencia; cuando se habla, por ejemplo, de usufructo de los créditos, se entiende inmediatamente lo que se quiere decir, mientras que sería más fatigoso, aunque más exacto, discurrir sobre una provisional cesión del derecho de exigir los intereses de un crédito y —si corresponde— el capital mismo, pero para retenerlo solamente hasta el término normal del usufructo.

*
* * *

Además, las cosas se distinguen entre sí de varios modos: algunas de estas distinciones dependen de la estructura de las

¹ En este sentido se habla de *res corporales* en D. 12, 6, 46; 23, 3, 39 pr.; 32, 95; 34, 4, 32 pr.; y también, no obstante la impresión contraria que se podría tener, en D. 3, 4, 8.

² Es evidente la interpolación de D. 10, 3, 4 pr. (ya destacada en el *Vocabularium iurispr. Rom.* de Berlín), y de D. 42, 1, 15, § 9; D. 41, 1, 43, § 1, es quizá corrompido (BESELER) o de cualquier modo gayano. Así también los textos donde *corpus* se contrapone a *ius*: p. ej., D. 39, 5, 9 pr. (BESELER); 44, 7, 3 pr. (PEROZZI); 37, 1, 3 pr. (BONFANTE); 39, 3, 8 (EISELE); 43, 26, 2, § 3 (ALBERTARIO); 39, 2, 13, § 1 (SEGRÉ); 5, 3, 18, § 2 (DE RUGIERO); en D. 44, 2, 7 pr., están interpoladas las palabras *vel in iure*.

cosas mismas o de las cualidades de ellas que influyen sobre la regulación jurídica; otras tienen su razón de ser sólo en las exigencias de la vida social. Comenzamos por el primer grupo de distinciones:

1º) *Cosas divisibles e indivisibles*. Se llaman divisibles las cosas que pueden dividirse en varias otras, cada una de las cuales conserva las características cualitativas y, con más o menos rigurosa proporción, la utilidad de la cosa originaria; indivisibles las que no pueden dividirse sin pérdida o disminución notable de su utilidad actual. Es divisible un fundo; es divisible por planos verticales una casa (salvo la necesidad del muro común); es indivisible toda cosa animada, toda máquina o utensilio; es indivisible un diamante que por su tamaño tenga un valor particular.

Pero también las cosas indivisibles son generalmente susceptibles de una división *intelectual*, o *ideal*, en el sentido de que se puede dividir su goce entre varias personas, de manera que cada una obtenga la utilidad de que es capaz, por una fracción correspondiente al derecho que sobre ella tiene frente a las otras; veremos cómo se produce esto al estudiar la institución de la copropiedad. Sólo entre las cosas incorpóreas se encuentran algunas que no pueden ser objeto ni siquiera de división intelectual: ejemplos típicos son las servidumbres prediales (no se puede admitir, por ejemplo, que yo goce *en parte* del derecho de hacer volver el agua de lluvia al patio del vecino).

2º) *Cosas simples, compuestas, universalidades de cosas*. La distinción está expresada con gran elegancia, y en términos tomados de la filosofía griega, en un pasaje de POMONIO, D. 41, 3, 30 pr. Cosa simple es la que los griegos llaman ἡνωμένον (cosa unitaria, *quae uno spiritu continetur*), es decir, la que es por naturaleza un solo todo; así, un bloque de mármol o una estatua esculpida en un bloque, un sér animado, una barca hecha con un tronco de árbol. Compuesta es, en cambio, la cosa que los griegos llaman συννημένον (*quod ex pluribus inter se cohaerentibus constat*), es decir, la constituida por varios fragmentos de la misma o de diversas materias, reunidos por la industria humana para servir a cierto destino: así, una nave, un armario, una casa. La distinción no es inútil, especialmente porque mientras la cosa simple dura cuanto lo permita su naturaleza o el uso que de ella se hace, la

cosa compuesta puede renovarse en sus partes conservando su individualidad, y hasta conserva esta individualidad, según un texto de ALFENO (D. 5, 1, 76) aunque después de varias sustituciones no subsista ninguna de sus partes originarias. En este sentido se puede decir, como lo ha visto ALFENO, que la cosa compuesta es más semejante a una *universitas* que a una cosa simple. *Universitas* (nombre probablemente posclásico) es *quod ex pluribus inter se distantibus constat*, es decir, un grupo de cosas naturalmente separadas, pero que a los fines económicos y jurídicos pueden considerarse bajo especie de unidad. El ejemplo típico es el del rebaño: los animales que lo componen pueden ser considerados aisladamente, pero el rebaño está sujeto a relaciones jurídicas también en su totalidad, y en este caso su subsistencia es independiente de la de las cabezas individuales. Por ejemplo, el usufructuario de una oveja hace suyos los corderos, que son frutos, y no debe restituír nada si la oveja muere de muerte natural; mientras que el usufructuario de un rebaño está obligado a sustituir con los que nacieron, las *capita demortua*, y sólo puede apropiarse, como fruto del rebaño, los incrementos netos.

Fuera del caso del rebaño y sus análogos (*equitium*, *armen-tum*), el concepto de *universitas* no tiene razón de ser: una galería de cuadros y una biblioteca no son más que la suma de los cuadros y de los libros, y usando el nombre colectivo no digo nada distinto de lo que diría si los nombrase uno por uno; en cuanto a la herencia, que también se suele referir bajo el mismo concepto, contraponiéndola como *universitas iuris* a las otras que serían *universitates facti*, BONFANTE ha demostrado que el concepto es antirromano y científicamente inútil.

3º) Cosas consumibles e inconsumibles. A la primera categoría pertenecen las cosas que no pueden ofrecer más de una vez a las personas a quienes pertenecen la utilidad que les es propia, en el sentido de que su uso consiste en destruirlas (por ejemplo, las mercancías) o transformarlas (las materias primas) o enajenarlas (el dinero); a la segunda, las cosas susceptibles de uso repetido. Las dos categorías, bien distinguidas por los clásicos, han sido algo confundidas por JUSTINIANO: véase el título de D. 7, 5, "de usu fructu earum rerum, quae usu consumuntur vel minuuntur", y el pasaje de las Instituciones (2, 4, 2) donde los *vestimenta* están

señalados entre las cosas que no pueden ser objeto de usufructo propiamente dicho³.

4º) *Cosas fungibles y no fungibles*. La inadecuada denominación, nacida de una frase romana totalmente inocente (*res quae in genere suo functionem recipiunt*: D. 12, 1, 2, 1), oculta un concepto bastante simple; es decir, que algunas cosas son consideradas comúnmente en su peso, número o medida (*res quae pondere numero mensura consistunt*), y otras, en cambio, lo son en su individualidad (*corpora, res corporales*). Pertenecen a la primera categoría las mercancías, el dinero, el papel, etc.; a la segunda los esclavos, los animales, los fundos, etc. Diferente es la distinción entre *genus* y *species*, que no es distinción entre las cosas, sino entre el concepto empírico de cierto grupo de cosas (el esclavo, el caballo) y la representación de las cosas individualizadas (el esclavo Stico, el caballo Pánfilo); en los negocios jurídicos puede tomarse como objeto tanto el *genus* como la *species*, y en consecuencia es, por ejemplo, obligación genérica la de dar un caballo, obligación específica la de dar tal caballo.

Por lo común, las normas jurídicas dictadas para las cosas consumibles presuponen la fungibilidad: así, el préstamo de consumo (*mutuo*) hace surgir la obligación de restituir otro tanto (lo que presupone la fungibilidad), y del mismo modo el cuasi usufructo, nacido para las cosas *quae usu consumuntur*, se resuelve en una trasferencia de propiedad con la obligación de restituir otro tanto al expirar el término. Esto depende del hecho de que normalmente lo que es consumible es también fungible, y viceversa: las cosas fungibles que no son, en rigor, consumibles (clavos, alfileres, etc.), sufren tales deterioros o pérdidas que están equiparadas, en la estimación social, a las consumibles⁴.

5º) *Cosas fructíferas y no fructíferas*. Son fructíferas las cosas que permaneciendo intactas y conservando su destino, dan más o menos periódicamente cierto producto que se convierte, a su vez, por separación natural o artificial, en cosa autónoma (fruto); son no fructíferas las otras. El caso más típico es precisamente el de la planta de fruto (el uso normal y el botánico de

³ Cfr. PAMPALONI, *Sull'oggetto del quasi usufrutto*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 19, 1907, ps. 85 y ss.

⁴ Sobre el asunto, cfr. Bensa, *Sul concetto di cose fungibili nel diritto italiano*, en los *Studi in onore di C. Fadda*, II, ps. 351 y ss.

la palabra derivan de la más amplia acepción jurídica); pero también son frutos en sentido jurídico las flores de las plantas florales, la leña de los bosques, la leche, la lana y las crías de las ovejas, etc. Sin embargo, los romanos han negado, desde los tiempos del jurista republicano BRUTO (siglo II a. C.) que fuesen frutos los nacidos de una esclava: la razón indicada por ULPIANO en D. 7, 1, 68 pr. ("neque enim in fructu hominis homo esse potest") y sustancialmente repetida por GAYO, en D. 22, 1, 28 § 1 ("cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit"), probaría verdaderamente demasiado, puesto que por deducción lógica habría debido llevar a la abolición de la esclavitud; más probablemente la razón decisiva ha sido que en el conflicto entre propietario y usufructuario de la esclava, ha parecido que el parto fuese demasiado precioso para poderse atribuir al segundo. Por el contrario, se consideran frutos también ciertos productos que no se renuevan, pero que disminuyen el valor total de la cosa en una medida normalmente muy leve: así, los productos de las canteras y de las minas.

Los frutos hasta aquí recordados se suelen llamar naturales; en antítesis con ellos, se llaman frutos civiles las sumas que pueden obtenerse periódicamente mediante la cesión del goce de una cosa a otro. En los casos más típicos, la relación con los frutos naturales debía ser evidente para los antiguos: así, el alquiler pagado por el arrendamiento de un terreno cultivable sustituye al reparto de los frutos naturales entre propietario y cultivador, y también el crédito fructífero, es decir, el mutuo a interés, representa el sucedáneo de un antiguo préstamo de animales o semillas, en el que se verificaba en realidad la producción de frutos naturales, y éstos eran atribuidos en parte a quien había entregado la cosa en préstamo⁵. Esta categoría de los frutos civiles se extiende aún a cosas naturalmente infructíferas, como las casas dadas en arrendamiento o los libros de una biblioteca circulante o los cuadros de una galería, accesible mediante tasa de ingreso; y en este sentido no hay cosa, corporal o incorporal, que no pueda ser fructífera.

⁵ Sobre este origen del mutuo, y sobre su relación con la altísima tasa del interés entre los pueblos primitivos, ver APPLETON, *Contribution à l'histoire du prêt à intérêt: Le taux du fenus unciarum*, en "Nouvelle Revue Historique", 43, 1919, ps. 467 y ss., y SCIALOJA, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 33, p. 240 (= *Studi giur.*, 2, 287).

6º) Cosas muebles e inmuebles. La distinción es considerada, en el derecho antiguo y en el clásico, solamente para casos particulares: así, para la usucapión, que se cumple en dos años para las *res soli* y en uno para las *ceterae res*. Únicamente en el derecho justinianeo la distinción adquiere importancia fundamental también a propósito de los modos de adquisición del dominio, como veremos al estudiar el desarrollo posclásico de la *traditio* (ps. 229 y ss.). Entre las cosas muebles (es decir, las que se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su estructura) tienen particular importancia las *moventes* o *semovientes* (esclavos y animales).

*
* *

La razón por la cual el derecho clásico pudo, en general, prescindir de la distinción entre muebles e inmuebles está en el hecho de que a la misma función proveía la antítesis entre las *res Mancipi* y las *nec Mancipi*. Las primeras son las cosas cuya propiedad, en cierto modo privilegiada, llevaba originariamente el nombre de *Mancipium*, y que se transmitían de sujeto a sujeto con un acto llamado al principio también *Mancipium*, y más tarde *Mancipatio*; *res nec Mancipi* son todas las otras. En la lista de las *Mancipi* entran los fundos itálicos, las servidumbres rústicas (o al menos las tres clásicas servidumbres de pasaje, *iter actus via*, y el *aqueductus*), los siervos, las bestias *quae collo dorsove domantur* (bueyes, caballos, asnos, mulas). Son, en suma, las cosas que en la vida económicosocial de una edad antiquísima constituían la parte más apreciada del patrimonio; y el signo manifiesto está en la innegable subsunción de las potestades familiares bajo la misma terminología (ver el nombre de *Mancipium* dado al esclavo, y el *in Mancipio esse* como servidumbre limitada de los hombres libres), como también en la unidad del acto (*Mancipatio*) que servía igualmente para transferir la propiedad sobre las *res Mancipi* y para transmitir las potestades familiares de uno a otro *pater familias*. El hecho de que en la nómina ocupen el primer puesto los fundos rústicos demuestra que la categoría ha tenido su ajuste definitivo en la época relativamente avanzada en que ha surgido la propiedad privada plebeya sobre los *agri divisi et adsignati* (p. 205); pero esto no impide que tenga un fundamento mu-

cho más antiguo, y que a él se vincule la pertenencia a la categoría de animales como los caballos y las mulas, que poco tienen que hacer con las exigencias propiamente dichas de la agricultura⁶. De todas maneras, la distinción entre *res Mancipi* y *nec Mancipi* subsiste durante todo el derecho clásico; pero sigue en la época posclásica la decadencia de la *mancipatio*; en fin, JUSTINIANO la suprime con una constitución del 531, reproducida en C. 7, 31, 1 (§ 5).

Pero a la cabeza del tratado de *rebus* se halla colocada, en el manual gayano, otra distinción: ella se expresa de diferentes modos, hablando ora de *res in patrimonio* y *extra patrimonium*, ora de *res in commercio* y *extra commercium* (o, más frecuentemente, *quarum commercium non est*); la primera forma de la antítesis se funda sobre el hecho de estar o no comprendida la cosa entre los bienes económicos de personas físicas o jurídicas; la segunda sobre el hecho de ser o no la cosa susceptible de relaciones de cambio, y, en general, de negocios jurídicos patrimoniales; por lo tanto, esta segunda terminología es mucho más precisa, porque bien pueden estar actualmente sin dueño cosas capaces de tenerlo (*res nullius* propiamente dichas, cfr. p. 210; *res derelictae* según la doctrina sabiniana, cfr. p. 211; *servus sine domino*, cfr. p. 275, n. 15). GAYO, que usa la primera terminología, la concilia a duras penas (como se ve por la confrontación entre los §§ 1 y 2 del libro II) con un diverso orden de ideas a que se atenía el viejo manual que él elaboraba: aquí se distinguía entre *res divini* y *humani*

⁶ Tengo presente, al lado del clásico estudio de BONFANTE (*Res Mancipi e nec Mancipi*, Roma, 1888-1889, nuevamente publicado bajo otro título en *Scr. giur. varii*, II, Torino, 1918, ps. 1 y ss.), también el excelente escrito de DE VISSCHER, *Mancipium et res Mancipi*, en "Stud. et Docum.", 2, 1936, ps. 263 y ss. No todo, en este escrito, me parece, por lo menos a primera vista, persuasivo; así, no me parece demostrado que en ciertos pasajes, máxime de las XII Tablas, *mancipium* signifique otra cosa que *mancipatio*, y muy en duda me dejan las reflexiones sobre el pretendido carácter aberrante y más reciente de la potestad sobre los esclavos. Sin embargo, encuentro bien aclarada la imposibilidad de vincular ciertas categorías de *res Mancipi* a las necesidades de la agricultura, y categóricamente probado que la palabra *mancipium* ha significado también, en los orígenes, el poder correspondiente al *pater familias* sobre cosas y personas. Nuestro gran BONFANTE, que a menudo me reprochaba ver una demasiado íntima analogía entre las potestades familiares y la propiedad, vería quizá también él en el concepto unitario de *mancipium* desentrañado por el colega belga, una preciosa mediación entre las tendencias opuestas.

iuris, y dentro de estas últimas entre *res publicae* y *privatae*; en la nueva terminología, las *res privatae* se identifican con las cosas *in patrimonio*, o *in commercio*, según quiera decirse, mientras que son *extra commercium* tanto las *res divini iuris* como las *publicae*⁷. Una tercera categoría de cosas *extra commercium*, *res communes omnium*, está descrita en las Instituciones justinianeas (2, 1, 1) sobre las huellas de un pasaje de MARCIANO (D. 1, 8, 2).

Refiriéndonos a los detalles, bastará recordar cuanto sigue:

1º) *Res divini iuris* son las destinadas al culto: se distinguen en *res sacrae*, destinadas al culto de los dioses superiores, y *res religiosae*, destinadas al de los dioses inferiores, especialmente de los manes de los antepasados, es decir, a hacerse propicias las potencias infernales y a evitar sus influencias maléficas, escrupulo supersticioso al que los romanos dan, precisamente, el nombre de *religio*. Son cosas sagradas los templos, los altares, los bosques sagrados; cuando provienen del patrimonio del Estado o de los ciudadanos, son destinados al culto con un acto solemne, en el que intervienen el magistrado y la autoridad religiosa, y que toma el nombre de *dedicatio* o *consecratio* según se lo considere desde el punto de vista de uno o de otra; igualmente, es necesaria una ceremonia religiosa (*profanatio*) para que la cosa pierda su carácter de sagrada. En el imperio cristiano son cosas sagradas las iglesias, las capillas, las dádivas votivas, "*quae rite et per pontifices deo consecrata sunt*" (1, 2, 1, 8)⁸. Entre las cosas religiosas ocupan, en cambio, el primer lugar los sepulcros: aquí no se requiere un acto de autoridad, sino que basta el sepelio del cadáver en lugar propio de quien provee al funeral. *Religiosum* es, en consecuencia, el sepulcro donde ha sido sepultado un cadáver (no el sepulcro que alguien se haya hecho construir para ser, a su tiempo, sepultado, ni el monumento erigido para simple

⁷ El relieve de la discordancia entre los §§ 1 y 2 es ahora la base del estudio de G. G. ARCHI, *La summa divisio rerum in Gaio e in Giust.* ("Stud. et Docum.", 3, 1937, ps. 5 y ss.); donde, sin embargo, no me parece feliz el esfuerzo por hacer coincidir las *res quae e. n. p. habentur* solamente con las *res divini iuris*. Aparte del sentido natural de la primera expresión, obsta insuperablemente a la conjetura, GAYO, II, 11. Véase también las observaciones de Grosso en *Studi Besta*, I, Milano, 1939, ps. 33 y ss.

⁸ Sobre el nuevo concepto de propiedad (inalienable) de la Iglesia, véase SCHERILLO, *Le cose*, I (Corso di dir. rom., 1944-1945), ps. 44 y ss. El libro está casi todo dedicado a las *res extra patrimonium*, y representa lo mejor que de algunos años a esta parte se haya escrito sobre la materia.

memoria); *religiosa* la urna que contiene las cenizas de la cremación; *religiosus* el *locus sepulchri*, es decir, aquella parte del fundo en que se halla el sepulcro. La extracomercialidad del sepulcro no significa que él no pueda ser objeto de relaciones jurídicas, pero sólo consiente las relaciones compatibles con su función: el titular del *ius sepulchri* tiene el derecho de *sepeliri et mortuum inferre*, derecho que es también transmisible en los límites del destino impuesto al lugar por el fundador, y siempre que éste no haya limitado rigurosamente el círculo de las personas que puedan ser acogidas en el sepulcro. Sobre la base de las disposiciones del fundador, los sepulcros entran la mayoría de las veces en la categoría de los *familiaria* o en la de los *hereditaria*; según la rígida concepción clásica, el sepulcro familiar se transmite de descendiente en descendiente, y a falta de descendientes pasa a la parentela agnaticia colateral, mientras que el sepulcro hereditario se transmite con el patrimonio, sin consideración a la pertenencia a la familia⁹.

A las *res divini iuris* están equiparadas, en cierto modo, las *sanctae*, puestas bajo la especial protección de los dioses, como los muros y las puertas de la ciudad: "*quodammodo divini iuris sunt*", dice a propósito GAYO (II, 8); y quizá alude con aquel *quodammodo* a una tendencia distinta que las colocaba entre las *res publicae*.

2º) *Res communes omnium* se dice de las que por naturaleza son accesibles a todos en cantidad ilimitada, de modo que cada uno puede gozar de ellas: el aire, el agua corriente como tal, el mar, por derecho justiniano también la ribera del mar. Se trata,

⁹ Cfr. ALBERTARIO, "Filangieri", 35, 1910, ps. 492 y ss., y en general sobre el régimen de los sepulcros, FADDA, *Studii e questioni di diritto*, I, 1910, ps. 147 y ss.; SCIALOJA, *Teoria della proprietà*, Roma, 1929, I, ps. 158 y ss.; y la documentación en mis *Negotia*, n.º. 80 a 86.

En las provincias, considerándose que el suelo sea propiedad del Estado, se excluye que el particular pueda hacerlo *religiosum* con el sepeleo; sin embargo, *pro religioso habetur* (GAYO, II, 7). También esta última norma parece negada por el γνώμων del ἱδίοις λόγος (§ 2), donde se afirma que por disposición de Adriano no hay entre los romanos nada de inalienable (ἀκαταχρημάτιστον), y que, por eso, también los sepulcros pueden ser vendidos por los romanos. Sobre las varias interpretaciones de este curioso pasaje, cfr. SCHOENBAUER, *Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechts im Altertum* [Contribuciones a la historia del derecho inmobiliario en la antigüedad], Leipzig, 1924, p. 105; ZANCAN, *Aegyptus*, 16, 1936, 148 y ss.; pero *adhuc sub iudice lis est*.

en realidad, de partes del mundo exterior que quedan fuera del campo del derecho, es decir, que no son cosas en sentido técnico (cfr. p. 181); antes que una prohibición legal de relaciones jurídicas patrimoniales que las tengan por objeto, se da aquí la imposibilidad, física o económica, de relaciones semejantes; el sistema de GAYO, que guarda silencio, es quizá preferible bajo este aspecto al sistema (¿marciano?-) justiniano¹⁰.

3º) *Res publicae* son, en el significado técnico que aquí interesa, las cosas del Estado *quae publico usui destinatae sunt*, como los ríos perennes (a diferencia de los torrentes), las calles, las plazas, los foros, los teatros, etc.; análogamente son *res universitatum* las pertenecientes, con igual destino, a los *municipia* y a las *coloniae*. Pero todo esto es todavía muy turbio en el pensamiento de los juristas romanos: para GAYO, por ejemplo, (II, 11), "*quae (res) publicae sunt, nullius videntur in bonis esse, ipsius enim universitatis esse creduntur*"; donde la expresión *nullius* significa que no son *privatae*, es decir, que están *extra nostrum patrimonium* en la terminología adoptada en un segundo tiempo por el mismo GAYO. De todos modos, los romanos no llegan a construir el derecho sobre las cosas de uso público como propiedad del Estado; más bien parecen oscilar entre la idea de una especie de condominio de todos los ciudadanos y el concepto publicístico de la soberanía territorial. Por el contrario, dan a menudo el nombre de *res publicae* también a aquellas cosas del Estado que no están sustraídas al comercio, sino que pueden ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales y pasar del patrimonio estatal al de los individuos. En suma, los juristas presintieron la distin-

¹⁰ La corriente contraria a las *res communes omnium* (MOMMSEN, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 2, 1889, p. 131; COSTA, *Le acque nel dir. rom.*, Bologna, 1919, ps. 99 y ss.; BONFANTE, *Corso di dir. rom.*, II, 1, ps. 42 y ss.; BETTI, *Dir. rom.*, p. 631), culminante en la opinión de PEROZZI (*Istituz.*, 2ª ed., I, ps. 596 y ss.; cfr. ya la 2ª edic. de este libro, p. 155, nº 1) de que la categoría sea justiniana, es hoy cruzada por otra corriente que la cree genuina (BIONDI, *Studi Perozzi*, ps. 269 y ss.; BUCKLAND, *Studi Riccobono*, I, ps. 279 y ss.; GROSSO, *Le cose*, 2ª ed., Torino, 1941, ps. 89 y ss.; BRANCA, *Le cose extra patr. humani iuris*, Trieste, 1941; SCHERILLO, *op. cit.*, ps. 69 y ss.). Ciertamente, se han puesto en claro notables asomos clásicos en el sentido de una separación del régimen del mar y de su ribera del de las *res publicae* en general; pero la contraposición dogmática de las *res communes* a las *res publicae* me parece excluida por ULPIANO (D. 43, 3, 1 pr.), mientras el pasaje de MARCIANO en D. 1, 8, 2; 4 pr.; 6 pr. (cfr. *Inst.*, 2, 1, 1-2), tiene elementos que me lo hacen siempre sospechoso.

ción entre bienes públicos (*demaniali*) y patrimoniales, pero no la desarrollaron científicamente¹¹.

Al lado de las *res quarum commercium non est*, encontramos a veces recordados por los romanos también seres que no son cosas, es decir los hombres libres. Que con ellos no pueda hacerse comercio es evidente; pero no porque sean cosas inenajenables, sino porque no son cosas. Y otro tanto se puede decir de las partes del cuerpo humano viviente para las cuales rige la regla: *dominus membrorum suorum nemo videtur* (D. 9, 2, 13). Si puede ser objeto de contrato el cadáver propio o ajeno, o las partes del cuerpo quirúrgica o naturalmente separadas, es problema que los romanos no se plantearon nunca.

FRANJA
MORADA

¹¹ La naturaleza elemental de este libro no me permite detenerme sobre los numerosos problemas a que da lugar la conciliación de las facultades de uso de las *res publicae* correspondientes a cada uno, con la análoga facultad de todos los otros. De particular interés es la cuestión relativa a las derivaciones de agua de los ríos públicos, para los cuales es cierto que el desenvolvimiento histórico va desde la libre derivación o arbitrio de los particulares hasta la especial concesión administrativa: pero los disensos son, sin embargo, muy profundos, especialmente en la doctrina italiana, que ha dedicado numerosas investigaciones al problema (véase principalmente VASSALLI, *Premesse storiche all'interpretazione della nuova legge sulle acque pubbliche*, Roma, 1917; BONFANTE, *Corso*, II, 1, ps. 80 y ss.; ALBERTARIO, *Studi in onore di O. Ranelletti* (1931), 2, ps. 291 y ss.; GROSSO, *Le cose* (Corso, 1940-1941), ps. 164 y ss.; LAURIA, "Annali Università Macerata", 8, 1932, ps. 243 y ss.; BRANCA, *op. cit.*, ps. 34 y ss. y 185 y ss.; SCHERILLO, *op. cit.*, ps. 131 y ss.

CAPÍTULO VI

LOS DERECHOS REALES: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

En el sistema de la ciencia moderna, un grupo de derechos subjetivos se reúne bajo la denominación de derechos reales o derechos sobre las cosas.

La denominación no es romana: la expresión *ius in re*, que pasa por tal, es, en cambio, propia de los romanistas del medievo. Lo que no impide que la separación entre esta categoría y la de los derechos de crédito o de obligación se remonte hasta el derecho romano, y hasta represente para los juristas clásicos uno de los puntos cardinales del sistema. Sin embargo, de conformidad con las tendencias fundamentales de su pensamiento (ps. 122 y ss.), los juristas plantean la distinción, antes que en el campo de los derechos subjetivos, en el de las acciones: en materia de defensa de los derechos patrimoniales, la *actio in rem* se contrapone a la *actio in personam*, y mientras la primera representa la posición avanzada de la propiedad y de los otros derechos sobre las cosas, la segunda es la defensa normal de los derechos de crédito.

GAYO, IV, 2-3: *In personam actio est, qua agimus cum aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare oportere. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut ius aliquod nobis competere, veluti utendi aut utendi fruendi, eundi agendi aquamve ducendi vel altius tollendi prospiciendive: <aut cum> actio ex diverso adversario est negativa.*

Como se ve, la distinción se funda totalmente sobre la *intento* (cfr. p. 143); la de la *actio in personam* afirma un deber jurídico del demandado, mientras la de la *actio in rem* la pertenencia al actor de una cosa o del derecho de obrar en cierta dirección respecto de una cosa, o la no pertenencia de igual derecho al

demandado. Mientras la acción *in personam* no puede concebirse sino en función del deber jurídico de otro, la acción *in rem* se dirige en primera línea hacia la cosa que es objeto del derecho pretendido: el demandado es un obstáculo que se interpone entre el actor y la cosa.

Esta concepción obedece a la estructura originaria del proceso (cfr. p. 130); y responde también a la representación inmediata que debieron tener los antiguos acerca de la propiedad, como de pertenencia absoluta de la cosa al individuo, *relación entre hombre y cosa a la cual los otros hombres son extraños*.

No se comprende, en cambio, cómo esta concepción primitiva e irreflexiva domine todavía hoy el pensamiento de muchos juristas, que definen el derecho real como una relación inmediata del hombre con la cosa. No desconocen que esta relación debe ser respetada por todos los demás, pero piensan que es respetada como una relación a la que se es extraño; esta exigencia sería ideológicamente un *posterius*, frente a la relación con la cosa, que definiría exactamente los derechos en cuestión.

Pero, ante todo, no se comprende dónde comienza y dónde termina la relación inmediata con la cosa. Está en relación inmediata con la cosa el propietario; otro tanto el usufructuario, que es también reconocido como titular de un derecho real; pero, ¿no está, acaso, en relación inmediata con la cosa también el locatario de un fundo o el inquilino de una casa? Sin embargo, los romanos le atribuyen una simple acción *in personam* contra el locador, y los modernos le niegan el derecho real. Otras veces, el mismo poder sobre la cosa puede ser atribuido al individuo tanto en virtud de un derecho real como de un derecho de obligación. Yo puedo, por ejemplo, ser titular de una servidumbre de pasaje; pero puedo también hacerme conceder por el vecino, por vía meramente contractual, la facultad de pasar a través de su fundo para trasladarme al mío: en uno y otro caso, mi relación con la cosa es absolutamente idéntica; si el primero es un derecho real y el segundo un derecho de crédito, la razón hay que buscarla en otra parte.

Pero el defecto principal de la concepción que combatimos consiste en olvidar que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas, es decir, de órdenes y prohibiciones que limitan la libertad de acción de los individuos, y que el derecho subjetivo, siendo una especial actitud de la norma misma, consiste en la facultad atribuí-

da al individuo de pretender de otros cierto comportamiento (cfr. ps. 19 y ss.). En un mundo en el cual, *per absurdum*, no existiere el derecho de propiedad (ni privada ni pública), no faltarían las relaciones entre los hombres y las cosas, pues todo hombre buscaría ponerse en relación con el mayor número posible de cosas; faltaría sólo el recíproco respeto de tales relaciones, y en torno de cada cosa se lucharía con la fuerza. Cuando la norma crea el derecho de propiedad, el fin es precisamente evitar esta lucha: sancionar un derecho subjetivo de propiedad significa prohibir a todos tomar ingerencia en aquella cosa que se quiere reservada a la libertad de acción de uno.

No podemos, pues, aceptar la doctrina (si así se le puede llamar) de la inmediata relación entre hombre y cosa, sino como una imagen¹; cuando haya elementos suficientes para que la imagen se presente, esto es, porque el particular pueda sentirse más bien en contacto con una cosa que en relación con otros individuos, entonces reconoceremos la existencia de un derecho real.

Ahora bien; para que la imagen se forme deben concurrir varias circunstancias:

1º) Que el titular del derecho saque ventaja de una cosa corporal. Los límites de esta ventaja son variables: desde la plena libertad de acción correspondiente al propietario, hasta la simple facultad de pasar por el fundo vecino, o de sacar agua de él, o de impedir que se abran ventanas en cierto frente.

2º) Que la norma jurídica que garantiza dicha ventaja, vincule hacia el titular no a una persona determinada sino a un número indefinido o a una serie de personas. Desde este punto de vista podría ser llevado, y muchos lo han sido efectivamente, a extender a todos los derechos reales aquella afirmación que ya hemos hecho sobre la propiedad; es decir, que frente al titular todos los coasociados estén obligados a abstenerse de cierta ingerencia en la cosa. Pero en realidad, es ésta una posición peculiar del derecho de propiedad. En materia de servidumbres prediales, en cambio, el poder del titular se reduce a pretender cierta abstención del propietario o poseedor del fundo sirviente: éste deberá abstenerse

¹ Grosso (*I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana*, Torino, 1944, espec. en las ps. 90 y ss.) sostiene elocuentemente que sea, en cambio, una realidad; y es, ciertamente, una realidad económica, pero —para quien como yo considera (contra Grosso) que el derecho sea un sistema de normas— no puede ser una realidad jurídica.

de abrir ventanas en la zona por la cual la existencia de la servidumbre se lo prohíbe, deberá abstenerse de impedir que yo pase por su fundo; todos los demás son verdaderamente extraños. Sin embargo, si la servidumbre es un derecho real, esto sucede porque a la abstención de que se trata está obligado no sólo el propietario o poseedor actual, sino todos los propietarios o poseedores sucesivos, de modo que el titular puede considerar su derecho como totalmente independiente de la existencia de ellos; sólo en esto su posición es distinta de la de quien se ha hecho conceder las mismas facultades a título puramente obligatorio, por el propietario actual². Análoga es la diferencia esencial que existe, para el derecho romano, entre el usufructuario y el locatario de un fundo.

3º) Que el comportamiento de la parte gravada sea negativo. Es el principio que los romanos expresan, para el caso particular de la servidumbre, con la máxima *servitus in faciendo consistere nequit*. La imagen de un poder inmediato del hombre sobre la cosa no puede surgir, y no surge, cuando al ejercicio del derecho corresponde la cooperación activa de otros. Así, por ejemplo, si un siervo o un hijo de familia comete un delito privado, como el hurto o el daño, la víctima puede pretender que quien tiene al culpable en potestad soporte personalmente la pena pecuniaria establecida para ese delito o le trasmita la potestad sobre el delincuente (*noxae deditio*); y esta pretensión le corresponde no ya frente a quien tenía en potestad al culpable en el momento del delito, sino contra quienquiera que lo tenga en el momento en que se intenta la acción (*actio noxalis*). La relación jurídica es, pues, también aquí ambulatoria, como la que existe entre el propietario del fundo dominante y el del fundo sirviente; pero puesto que se exige del amo o padre de familia (quienquiera que él sea) un com-

² Contrá este modo de concebir la servidumbre, BETTI ("Bull. Ist. Dir. Rom.", 34, ps. 284 y ss.) ha levantado objeciones agudísimas. Pero yo continúo sin entender cómo se puede hablar de *sujeción* del fundo al titular de la servidumbre como de un *prius* respecto a la norma que impone la prohibición al propietario del fundo sirviente: ¿qué significa, frente a un sistema de normas (inevitablemente dirigidas, como tales, hacia las voluntades), sujetar los fondos? Más útil es el concepto del *límite de la propiedad*, sobre el cual también BETTI insiste; pero, para que tal definición funcionase contra mi construcción, correspondería considerar la propiedad del fundo sirviente como irremediabilmente despojada de aquellas facultades que se han convertido en servidumbre; a cuya consideración obstaría el concepto de la elasticidad del dominio.

portamiento positivo, la idea del derecho real no surge, y se permanece en el campo de las relaciones de obligación³. Así también, contra el propietario del fundo vecino sobre el cual se hayan construido canales o diques para hacer volver a mi fundo el agua de lluvia, yo tengo una pretensión, tutelada por la *actio aquae pluviae arcendae*, para que se remuevan aquellas obras, y esta pretensión puedo hacerla valer tanto contra el propietario autor de la obra como contra los sucesivos propietarios; pero puesto que pretendiendo un comportamiento positivo, el derecho no es real.

Todo lo que hemos dicho vale para el derecho romano y también —en sustancia— para nuestro derecho: en otros ambientes jurídicos, una facultad más sobresaliente de abstracción puede hacer reconocer derechos reales también donde a los romanos y a nosotros repugna reconocerlos; por ejemplo, muchos autores han podido reconocer en Alemania el carácter de realidad a las llamadas cargas reales (*Reallasten*), consistentes, por lo general, en prestaciones pecuniarias debidas por todos los sucesivos propietarios y poseedores de un fundo. Los conceptos empíricos que son propios de la ciencia jurídica no pueden aspirar a una absoluta

³ Consideraciones análogas a las arriba expuestas, y sobre todo el examen de las reglas procesales destinadas a garantizar la ambulatoriedad de la obligación, han conducido a BRONDI (*Actiones noxales*, en "Annali Semin. Giur. Palermo", 10, 1925) a definir la *actio noxalis* como una *vindicatio* del culpable por parte del ofendido. No niego que la construcción presente, desde un punto de vista abstractamente dogmático, grandes atractivos; mientras, en efecto, ella daría plena razón de la facultad del que ejerce la potestad de evitar el juicio abandonando al culpable, representaría también con extrema energía la idea primordial de la venganza, a cuya actuación sobre el culpable pone un obstáculo la potestad del *dominus* o *pater familias*. Pero no parece que haya sido lograda por BRONDI la demostración de alguna analogía de estructura entre las fórmulas noxales y las de las acciones *in rem*: las primeras llevan en la *intentio* no la indicación de un derecho del ofendido, sino la enunciación del delito del sujeto a potestad, y la *condemnatio* trasfiere a nombre del que ejerce la potestad la obligación de soportar la pena pecuniaria, con el simple agregado de la facultad *noxae dedendi*. Prácticamente, pues, el proceso noxal debía desembocar habitualmente en el pago de la pena: la cosa es intuitiva no sólo para los delitos de los hijos de familia, sino que también para los delitos de los esclavos se habrá encontrado casi siempre una desproporción tal entre la suma de la condena y el valor del esclavo, que haría evitar a toda costa la *noxae deditio*. Vimos, en cambio (p. 156), que, no obstante el principio de la pecuniariedad de la condena, la *vindicatio* desembocaba normalmente en la voluntaria restitución por parte del demandado.

validez, que los haga inmutables de tiempo a tiempo y de lugar a lugar.

*
* *
*

De cuanto hemos dicho se desprende que entre los derechos reales ocupa una posición eminente la propiedad (también los romanos usan la mayoría de las veces la expresión *actio in rem* como sinónimo de *rei vindicatio*, volviendo la atención solamente a la acción en tutela de la propiedad); en antítesis con ella, todos los otros derechos sobre las cosas toman el nombre de *iura in re aliena*. Entre éstos, pertenecen al antiguo derecho romano las servidumbres prediales (*servitutes* o *iura praediorum*) y el usufructo, con su atenuación que es el *usus*; los compiladores justinianos los reúnen bajo la única denominación de *servitutes*, que distinguen en *servitutes personarum* (constituídas en ventaja de las personas) y *praediorum* (constituídas en ventaja de los fundos)⁴. Origen mucho menos antiguo tienen la enfiteusis y la superficie: ambas, en efecto, tuvieron su regulación definitiva en el Bajo Imperio, y mientras a la enfiteusis puede reconocérsele un precedente clásico en el *ius in agro vectigali*, la superficie parece haber sido propiamente reconocida como derecho real solamente en la época posclásica. La prenda y la hipoteca tienen en común la característica de su destino como garantía de las obligaciones, de donde deriva el nombre de derechos reales de garantía: su construcción como derechos reales, tampoco plenamente desarrollada por los juristas, comienza, sin embargo, a delinearse desde el último siglo de la República.

⁴ Sobre el carácter justiniano de esta terminología, y sobre las interpolaciones hechas en los textos clásicos para introducirla en ellos, cfr. LONGO, *La categoria delle servitutes nel dir. rom. classico*, en el "Bull. Ist. Dir. Rom.", 11, 1899, ps. 281 y ss.

CAPÍTULO VII

LA PROPIEDAD

§ 1. DEFINICIÓN. LOS DIVERSOS TIPOS DE PROPIEDAD EN EL DERECHO ROMANO

La propiedad es el señorío del hombre sobre la cosa, garantizado por el derecho objetivo mediante la exclusión de toda ingerencia extraña; es el derecho en virtud del cual la voluntad del titular es decisiva respecto a la cosa en toda dirección (WINDSCHEID). Esta relación de pertenencia resalta también en el lenguaje común, que acostumbra señalar la propiedad con los mismos adjetivos posesivos con que se señalan los órganos y las facultades corporales y espirituales del hombre; así como hablo de *mis* manos y de *mi* pensamiento, también, con las palabras del formulario de la antigua *legis actio sacramenti*, "*aio hunc hominem, hanc domum, hoc volumen meum esse*", expreso casi que en aquellas cosas del mundo exterior se refleja y actúa mi personalidad.

Para definir la amplitud del señorío correspondiente al propietario, los juristas del derecho común solían partir de la definición del usufructo, que es *ius utendi fruendi*, y agregarle un *ius abutendi*, en el que se comprendería la facultad de enajenar la cosa, de abandonarla, de destruirla. Con esto se omitía la facultad que desde el punto de vista jurídico constituye el elemento más notable de la propiedad; es decir, la exclusión de cualquier ingerencia de terceros respecto a la cosa. Pero quizá tan unilateral como ésta es, en razón de faltarle toda consideración al contenido económico de la relación, la definición que de la propiedad dan juristas excesivamente severos, como SCHLOSSMANN, considerándola como *derecho de exclusión*.

Lo que hemos dicho no impide que la facultad de gozar de la cosa en algunas direcciones pueda corresponder a persona distinta del propietario (ejemplo, usufructuario, enfiteuta) o al propietario y a otros conjuntamente (ejemplo, servidumbre de tránsito), o, en fin, que el propietario pueda estar obligado con respecto a otros a abstenerse de ciertos actos de goce (ejemplo, *servitus altius non tollendi*). Pero es característico que los derechos sobre la cosa de otro, así definidos (los llamados derechos reales fraccionarios), no representan poderes definitivamente separados de la propiedad; por el contrario, toda vez que el derecho de otro se extinga, las facultades en él comprendidas vuelven *ipso iure* al propietario. Es éste el principio de la *elasticidad del dominio*.

Particularmente absoluta y preponderante es la propiedad fundiaria romana. En los orígenes, los derechos reales que pueden limitarla son solamente el usufructo y las servidumbres voluntariamente constituídas; pero el primero es esencialmente temporario, y para las segundas el nombre mismo nos dice que son consideradas como situaciones anormales de sujeción de un fundo a otro. Normalmente, el fundo pertenece a su señor tan plenamente como el territorio al Estado, y esta completa exención de cargas se expresa en los formularios dando al fundo no gravado con servidumbre las calificaciones de *optimus maximus*.

También en las relaciones entre vecinos, la libertad de que goza cada uno de las ingerencias de otros, es la que decide; en efecto, no puede considerarse como límite a la actividad del particular, sino como discriminación de las respectivas esferas de libertad de acción, la prohibición de turbar al vecino con actividades que, aun desarrollándose sobre el fundo propio, representen para aquél la más mínima invasión o *immissione*. La regla fundamental está dada por ULPiano, sobre las huellas de ARISTON, en D. 8, 5, 8 § 5: "In suo... alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat"; en consecuencia, se decide que no es lícito al propietario de una fábrica de quesos invadir con el humo que de ella proviene el edificio superior, que no es lícito al propietario de un fundo superior echar agua en el fundo inferior, que no es lícito picar piedra en el fundo propio haciendo saltar los fragmentos sobre el fundo vecino. Naturalmente, tal criterio encuentra su aplicación conforme a las costumbres y a las exigencias prácticas: en el § 6 del mismo fragmento, ULPiano ad-

mite, por ejemplo, que es lícito "*fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere*", aunque parte de ese humo suba al edificio superior.

De todo lo dicho resulta cuán antirromana es esa prohibición de los actos de emulación, que los juristas medievales creyeron extraer de nuestras fuentes y llevaron a consecuencias extremadamente nocivas para la sana economía fundiaria. Se llamaron de emulación los actos que un propietario realiza sobre su cosa, no para obtener una utilidad efectiva, sino con el único fin de molestar al vecino: como si yo encendiese fuego no para entrar en calor ni para cocer alimentos, sino para causar una incomodidad al vecino con el humo que de aquél proviene, o si, teniendo una casa ya ampliamente iluminada, abriese una ventana con el solo fin de poder curiosear en el jardín de otro. Criterio, como es fácil de ver, extraordinariamente peligroso; sobre todo porque, faltando la mayoría de las veces el modo de investigar los móviles del propietario, a la demostración del propósito exclusivo de perjudicar se sustituían las presunciones, con evidente daño para la iniciativa individual. Para descartar que un principio como el de la prohibición de los actos de emulación fuese conocido por los juristas romanos, bastaría recordar la máxima *nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur*. Ciertamente es que algún pasaje de la compilación justiniana, relativo a la mejor distribución de las aguas, parece inspirarse en la aversión por los actos emulativos¹; pero PEROZZI² ha demostrado que esos pasajes fueron retocados por los compiladores.

Sin embargo, alguna verdadera limitación impuesta a la propiedad, sea en interés público o en el de los vecinos en condiciones de necesidad, existe también en el derecho romano, con frecuencia siempre mayor con el correr de los siglos. Quizá no entra en este concepto el *limes*, espacio de cinco pies que en el acto de las asignaciones de tierras se dejaba libre alrededor de cada lote de terreno; y tampoco el *ambitus*, espacio igual que debía dejarse libre entre edificio y edificio. Es dudoso, en efecto, si aquellas pequeñas zonas se consideraban asignadas o permanecían públicas; y en la primera hipótesis, hay todavía dudas sobre si fuesen inmediatamente abandonadas por los asignatarios para transformarlas en

¹ En sentido contrario, SCIALOJA, voz *Aemulatio*, en "Enc. Giur. Ital." (= *Studi giur.*, 3, ps. 218 y ss.); de otra manera, M. ROTONDI, *L'abuso di diritto*, en "Riv. di Dir. Civ.", 1923, espec. en las ps. 219 y ss.

² "Archivio Giuridico", 53, 1896, ps. 350 y ss.

vías públicas, o si, por el contrario, permanecieran de propiedad privada pero con afectación al uso público: sólo en el último caso se podría hablar con propiedad de una limitación del dominio.

Donde no existe *limes* (lo que era quizá ya normal en la época clásica) el acceso a la vía pública a través del fundo del vecino no puede obtenerse sino mediante constitución de servidumbre, nunca —en consecuencia— contra la voluntad del propietario gravado. Sólo se ha derogado este principio para el *iter ad sepulchrum*, el cual, según una constitución de SEVERO y CARACALLA referida en D. 11, 7, 12 pr., debe ser precariamente concedido por el vecino con la mediación del presidente de la provincia, a quien el interesado puede dirigirse, según parece, como a un amigable componedor³. Sobre los fundos situados a lo largo de un río recae un derecho de uso público para las necesidades de la navegación y del comercio fluvial; y si una vía pública es obstruida, los propietarios de los fundos ubicados a lo largo de ella deben permitir el tránsito a los transeúntes hasta que aquélla vuelva a ser utilizable.

Señalamos todavía, respecto a los edificios, una serie de disposiciones repetidamente confirmadas y retocadas en la época imperial, dirigidas a evitar las demoliciones injustificadas, a no turbar los planos regulares de las ciudades, a limitar la edificación sobre los locales destinados a baños, a impedir que sean separados de las casas los mármoles y otros materiales valiosos que contribuyen a la magnificencia de las ciudades (cfr. sobre todo esto las constituciones del C. 8, 10, de *aedificiis privatis*)⁴.

El derecho posclásico admite también con amplitud la expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización

³ El texto es, sin duda, interpolado; pero no me parece demostrado que sea mero fruto de interpolación la intervención del presidente, como sostienen PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, p. 636, y BONFANTE, *Corso*, II, 1, p. 280. Me parece cierta, por otra parte, la interpolación del pasaje de Ulpiano en D. 8, 5, 1, donde se aplicaría a la *via* (¿por qué no *iter*?) *ad sep.* la normal *vindicatio* de las servidumbres de tránsito (la sospecha está ya en LENEL, *Ed. perp.*, 3ª ed., p. 141, n° 2).

⁴ Se discute, en cambio, si puede reconocerse, por lo menos para el derecho justinianeo, un sistema de "servidumbres legales" (por ejemplo, *altius non tollendi*, *luminum*, etc.) que limiten la propiedad urbana. La *communis opinio* está más bien en sentido negativo; pero ver en contra, CLAPESSE, *Studi sc. giur. e soc. Univ. Pavia*, 1937, ps. 25 y ss., y BIONDI, *La categoria romana delle servitutes*, Milano, 1939, ps. 75 y ss. Ver también más adelante, p. 276, n. 18.

(cfr., por ejemplo, C. 8, 11, 9); respecto del tiempo anterior no tenemos disposiciones generales, pero es cierto que desde la última época de la república las leyes especiales relativas a la construcción de toda obra pública regulaban la situación de los propietarios que habrían debido ser privados de sus bienes⁵.

Veremos inmediatamente (§ 3) los medios judiciales que para tutelar el pleno ejercicio del derecho de propiedad frente a los vecinos, limitan en cierto sentido la propiedad de éstos (*interdicta de arboribus caedendis y de glande legenda, actio aquae pluviae arcendae, cautio damni infecti, operis novi nunciatio, interdictum quod vi aut clam*).

*
* *

Hemos tratado hasta ahora de la propiedad como de una institución unitaria; corresponde, sin embargo, poner de relieve que en el derecho clásico se pueden distinguir tres diversos tipos de situaciones jurídicas que, consideradas en su contenido económico y en la protección *adversus omnes* de que gozan, pueden designarse todas como propiedad. Tales son, según la terminología moderna, la propiedad civil o quiritaria (*dominium ex iure Quiritium*), la propiedad provincial (*usufructus* o *possessio* de los *praedia stipendiaria* o *tributaria*), la propiedad pretoria o bonitaria (*in bonis habere*).

La distinción entre el primero y el segundo tipo, que es específica de la propiedad fundiaria, responde en sus presupuestos a concepciones fundamentales de la antigüedad⁶. Esencialmente, soberanía y propiedad fundiaria eran, en la concepción originaria,

⁵ El problema ha sido objeto de una larga y brillante polémica entre SCIALOJA (por último en *Teoria della proprietà*, I, 1928, ps. 315 y ss.) y BONEANTE (*Corso di dir. rom.*, II, 1, 1926, ps. 237 y ss.). Ahora todo el material de la disputa está recogido en DE ROBERTIS, *L'espropriaç. per pubbl. utilità*, Bari, 1936.

⁶ Para los diversos aspectos del tema cfr. por último, con doctrinas notablemente discordes, los estudios de ZANCAN, *Ager publicus*, Padova, 1935; BOZZA, *Ag. publ.*, Napoli, 1939; CARRELLI, "Stud. e Docum.", I, 1935, ps. 379 y ss.; MONIER, *Manuel*, I, 6ª ed., ps. 356 y ss.; como así también los estudios del flamenco WILMS resumidos por CORNIL en la "Festschr. Koschaker", 1939, I, ps. 404 y ss. Por último, véase KASER, "Rev. Fundac. Savigny", 62, 1942, ps. 1 y ss.

la misma cosa; de manera que la tierra no podía pertenecer al particular, sino al monarca despótico o, colectivamente, a los cives de una ciudad. Sólo después y únicamente en el régimen del Estado-ciudad, la copropiedad soberana de todos se transforma en propiedad del particular sobre la fracción que se le ha asignado como su parte (o supuesta tal).

Para los principios de Roma, en efecto, no nos resulta probada la existencia de una propiedad privada de los fundos cultivables; cuando mucho, una propiedad inmobiliaria de los particulares se reconoció en la ciudad solamente sobre las casas, como también sobre pequeños lotes cultivados en calidad de huertos (véase los *bina iugera*, constitutivos del *heredium* que Rómulo habría asignado a cada ciudadano). El territorio que queda fuera de la ciudad se destina al pastoreo o a la agricultura extensiva, principales fuentes de vida de las "gentes" patricias: se trataba, en su mayor parte, de territorio del cual se habían apoderado los etruscos cuando fundaron la ciudad, de manera que cada uno de ellos (patricios) lo podía ocupar con sus rebaños (de allí el nombre de *ager occupatorius*), salvo que su derecho era precario y revocable por la ciudad a su arbitrio (y por eso se le llamaba *possessio*). Después, la agricultura intensiva se impone con el consiguiente predominio del pueblo agricultor de los plebeyos contra la minoría patricia; y la preponderancia de tal forma de agricultura se traduce en la exigencia de un señorío no ya precario y revocable sino permanente e intangible, de cada familia de campesinos, sobre su fracción de terreno⁷. En la tradición tiene particular relieve la distribución del territorio tomado a los veyenses, después de la victoria de Camilo, en 396 a. C.; se hicieron con él muchos pequeños lotes de siete yugadas cada uno, que se asignaron a las familias plebeyas. Pero las asignaciones habían tenido ya lugar en gran número, sea en tierras tomadas a los enemigos, sea quizá dentro del mismo *ager publicus* originario; posteriormente, las asignaciones se extendieron cada vez más, y se fueron creando, en todas partes de Italia, colonias de ciudadanos o de latinos que allí se establecían en condiciones análogas. La asignación estaba precedida por la *limitatio*, a la que se procedía mediante ceremonias augu-

⁷ Véase en C. I. L., I, 551, la inscripción del cónsul C. Popilio Lena (132 a. C.): "primus feci ut de agro poplico aratoribus cederent pastores". Es, como se ve, el concepto originario, que así se revela todavía vivo en la época de los Gracos.

rales: señaladas dos calles maestras, una según el curso del sol y la otra de norte a sud (*cardo maximus* y *decumanus m.*), se trazaban paralelamente a una y otra las que debían ser las líneas de confín entre los lotes; su asignación se hacía normalmente mediante sorteo. El *ager divisus et adsignatus* era, entre los terrenos, el único que podía ser objeto de propiedad privada, el único que el propietario podía reivindicar declarando: "aio hunc fundum meum esse ex iure Quiritium".

En cambio, el *ager publicus*, al que también se fueron agregando nuevas zonas con cada extensión notable del territorio romano, siempre permaneció objeto de simple posesión, aunque la precariedad de la ocupación llegase a ser un puro nombre, y el señorío de hecho sobre vastas zonas territoriales formase parte notable del patrimonio de las grandes familias. De todos modos, cuando en 133 a. C., Tiberio Graco propugnó el retorno de parte de la tierra pública al Estado y su distribución como *ager divisus et adsignatus*, el Senado no pudo oponerle argumentos jurídicos sino solamente el obstruccionismo. Votada la ley de Graco, multiplicadas en los años sucesivos las asignaciones (especialmente a los veteranos de los ejércitos proconsulares del último período republicano), trasformada, por el contrario, en propiedad de pleno derecho aquella *possessio* que volvía a entrar en los límites fijados por las nuevas leyes, ya no hubo en Italia tierras cultivables que no fuesen asignadas en dominio quiritario; de allí la definitiva subsunción de todos los *fundos itálicos* entre las *res Mancipi*.

Pero el territorio de las provincias, que había estado la mayor parte de las veces en la propiedad-soberanía de las dinastías orientales y helenísticas, pasó naturalmente a la propiedad del Estado romano, para después ser dividido (en el dualismo de la constitución augustea) entre la república, representada por el Senado, y el príncipe, su protector; y fué objeto de una explotación racional, tanto más necesaria en cuanto la decadencia del cultivo de cereales en Italia imponía una enorme importación, y los grandes gastos públicos no podían ser atendidos sin extraer de las provincias cuanto dinero se pudiese. Sobre los diferentes métodos de explotación diremos algo a propósito de la enfiteusis (cap. ix); aquí sólo corresponde señalar que también de los terrenos que se dejaban a los particulares en pleno y transferible goce (γῆ ιδιόκτητος, según la terminología de las provincias helenísticas) permanecía como propietario el Estado o el príncipe; como reconocimiento

de este derecho eminente el concesionario estaba obligado al pago de un impuesto, llamado *stipendium* en las provincias senatoriales y *tributum* en las imperiales. El nombre de *dominium* no es aplicable a esta forma de señorío: GAYO (II, 7 y *passim*) intenta más bien expresar su contenido recurriendo todavía una vez más a la terminología de las leyes sobre el *ager publicus*, que hablaban de *habere possidere uti frui licere*; dice, por consiguiente, que en él *possessionem tantum vel usumfructum habere videmur*. Lo cierto es que tenemos aquí una institución afín a la propiedad, salvo la limitación del impuesto; en el Edicto emanado de los gobernadores de las provincias senatoriales, al rubro de *rei vindicatione* seguía el otro *si ager stipendiarius petatur*, bajo el cual debía acordarse una fórmula análoga a la de la *rei vindicatio* misma, y ciertamente en su jurisdicción toda otra acción en defensa de la propiedad fundiaria debió ser adaptada a la cuasi propiedad; análogamente proveían en los expedientes de la *cognitio extra ordinem*, los presidentes de las provincias imperiales.

Sólo en el Bajo Imperio se abolió la distinción. El primer paso se dió en el siglo III, cuando Aureliano gravó con impuestos también a los fundos itálicos; desde ese momento cesaba toda razón para un tratamiento diferente, y si alguna diferencia de regulación jurídica se ha conservado durante algún tiempo, esto no ha podido ocurrir más que por fuerza de la inercia. Pero ahora se planteaba el dilema: declarar, en obsequio a la tradición jurídica, excluida toda propiedad individual para los inmuebles, o renunciar a considerar el pago del impuesto como reconocimiento de una propiedad eminente del Estado, para entenderlo como contribución del propietario a los gastos públicos. Eligiendo este segundo camino, el más razonable, se reconoció también en las provincias el *dominium*, el cual ya no es más *ex iure Quiritium*, por haber desaparecido esta denominación con las fórmulas procesales clásicas que la contenían, pero conserva los principales atributos de la propiedad clásica.

En otro sentido, y para toda clase de objetos, a la propiedad quiritaria se le fué oponiendo una propiedad pretoria. La adquisición de la propiedad civil está vinculada, como veremos, para las *res Mancipi*, al cumplimiento del acto solemne, *mancipatio* o *in iure cessio*; dondequiera que éste no haya tenido lugar, el adquirente no se hace *dominus ex iure Quiritium*. Ahora bien; por razones inherentes a las más elementales exigencias del comercio,

el pretor consideró necesario proteger en ciertos casos al adquirente, ya contra terceros, ya eventualmente contra el mismo propietario, como si el vicio de forma no existiese.

El caso privilegiado (el único, quizá, del cual el Edicto hiciese mención) es el de una *res Mancipi* vendida y después transmitida al comprador mediante la simple entrega (*traditio*). Por el principio del *ius civile*, el transmitente permanecía como propietario hasta que no se hubiese cumplido en provecho del *accipiens* la usucapición; y podía en el intervalo intentar victoriosamente la *rei vindicatio*. Pero el pretor paraliza la eficacia de esta acción otorgando al comprador la *exceptio rei venditae et traditae*, mediante la cual él permanece en posesión de la cosa y es absuelto (cfr. ps. 148 y ss.). En el caso de que durante el mismo período de tiempo un tercero llegase a ser poseedor de la cosa, no pudiéndose permitir al adquirente el ejercicio de la *rei vindicatio*, el pretor le concede una fórmula ficticia llamada (por el nombre del magistrado o jurista que la inventó) *actio Publiciana*, consistente en ordenar al juez que investigue solamente si ha tenido lugar la venta y la sucesiva tradición, para obrar, en caso afirmativo, como si hubiese transcurrido también el término de la usucapición (ps. 145 y ss.). La *Publiciana* puede también intentarse contra el propietario vendedor, en la eventualidad de haber recobrado la posesión de la cosa suya; es verdad que él gozaría de una *exceptio iusti domini* que en otras circunstancias paralizaría la acción, pero aquí la excepción es paralizada a su vez por una *replacatio doli*, concedida al actor en consideración a la conducta maliciosa que el propietario observaría al tratar de conservar la cosa por él mismo vendida y entregada. La protección ideada para el comprador, fué pronto extendida a quien hubiese recibido la entrega de la cosa *Mancipi* por una causa distinta de la compraventa, como la donación o la constitución de dote.

Los mismos medios judiciales (o, eventualmente, otros medios análogos) se aplicaron toda vez que una cosa hubiese pasado del señorío de una persona al de otra, sobre la base de instituciones de creación pretoriana; dado, en efecto, el dualismo de los ordenamientos, no podía un medio jurídico creado o adaptado por el pretor conferir la propiedad civil.

Piénsese, por ejemplo, en la distinción entre los *iudicia legitima* y los *iudicia quae imperio continentur* (p. 157): si un juicio divisorio (*communi dividundo* o *familiae erciscundae*) se ha des-

arrollado como *iud. q. imp. continetur*, el adjudicatario sólo puede disponer de la *actio Publiciana*. Por analogía, tendremos que decir que quien paga el importe de la condena (*litis aestimatio*, cfr. p. 156) como consecuencia de una *rei vindicatio* planteada como *iud. leg.* se hace propietario *ex iure Quiritium*, y que, en cambio, quien lo paga como consecuencia de una *rei vindicatio* planteada como *i. q. i. c.*, podrá luego defenderse, salvo usucapión, sólo con la *Publiciana*.

Lo mismo ocurrirá, como es natural, para todas las acciones pretorias; por ejemplo, si demandado con la *Publiciana* misma yo prefiero pagar la *litis aestimatio* antes que entregar la cosa, no podré adquirir un derecho más fuerte que el que correspondía al actor a quien pago.

Prosiguiendo con la analogía, cabe señalar que mientras el heredero civil puede reclamar los bienes particulares de la herencia con la *rei vindicatio*, el heredero pretorio (*bonorum possessor*) sólo puede reclamarlos mientras no haya usucapido, con una acción ficticia análoga a la *Publiciana*; que mientras el adrogante (adoptante de una persona *sui iuris*) adquiere la propiedad civil de los bienes del adrogado, el *bonorum emptor*, adquiriendo como consecuencia de un procedimiento de creación pretoria (ps. 161 y ss.), sólo tiene una defensa pretoria; y así sucesivamente.

En las hipótesis analizadas, del adquirente que mediante los mecanismos de la *actio Publiciana* y de la *exceptio rei venditae et traditae* hace valer, contra quienquiera que sea, su facultad de permanecer en posesión, se dice que tiene la cosa *in bonis*, es decir, en propia, exclusiva y perpetua disposición⁸. Prácticamente él es el propietario; mientras que al dueño formal, a quien sería inicuo reservar la posesión, le queda un *nudum ius Quiritium*, es decir un derecho de propiedad desprovisto de toda ventaja. Por eso se comenzó a hablar abusivamente, ya en la época clásica, de dos

⁸ Distinta es la situación de aquel que haya adquirido de quien no era propietario; este adquirente estará defendido por la *Publiciana* y por la *exceptio* recordada, tanto contra cualquier tercero poseedor como contra su causahabiente; pero sucumbirá frente al verdadero propietario (cfr. p. 234). Si, en efecto, el *dominus* reivindica, el poseedor no puede oponerle una venta con la sucesiva entrega hecha por otro; en cambio, si el *dominus* llega a entrar de cualquier modo en posesión, y el adquirente intenta contra él la *Publiciana*, ésta es paralizada por la *exceptio iusti dominii*. Respecto a la usucapión, en cambio, como veremos en la p. 233, y siempre que haya justo título y buena fe, la posesión del adquirente sin acto solemne y la del adquirente a *non domino* son iguales.

tipos de *dominium*, el *ex iure Quiritium* y el *in bonis*; y, abolida la *mancipatio* y la *in iure cessio*, JUSTINIANO elevó a la condición de casos de propiedad civil a todos aquellos en que los clásicos habían reconocido el *in bonis*.

Por lo tanto, en el derecho justiniano se logra plenamente la unificación del concepto de propiedad.

§ 2. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD

Distinciones fundamentales. Modos de adquisición a título originario: 1) ocupación y adquisición del tesoro; 2) accesión; 3) incrementos fluviales; 4) especificación; 5) confusión y mezcla; 6) adjudicación; 7) *litis aestimatio*; 8) adquisición de los frutos. Modos de adquisición a título derivado (transmisión): principios generales. Los modos particulares; 9) *in iure cessio*; 10) *mancipatio*; 11) *traditio*. Modos de adquisición intermedios entre los a título originario y a título derivado: 12) usucapión y *praescriptio longi temporis*. Pérdida de la propiedad.

Se llaman *modos de adquisición de la propiedad* aquellos hechos jurídicos que el ordenamiento declara idóneos para crear en los particulares un derecho de propiedad, o para transmitirlo de uno a otro sujeto.

Estos hechos jurídicos son clasificados por los juristas, y especialmente por GAYO, en dos grandes categorías: modos de adquisición *iuris gentium*, es decir, inspirados en una *naturalis ratio* y, en consecuencia, accesibles tanto a los extranjeros como a los romanos, y modos de adquisición *iuris civilis*, es decir, propios de los romanos. A la primera categoría pertenecen, por ejemplo, la ocupación (especialmente en la forma de la *occupatio bellica*) y la tradición; a la segunda, la *mancipatio* y la usucapión.

Mucho más grata a los modernos es la distinción entre modos de adquisición *a título originario* y *a título derivado*⁹. La propiedad se adquiere a título derivado cuando la causa de la adquisición está en la transmisión efectuada en nuestro beneficio por el precedente propietario; se adquiere a título originario cuando falta tal conexión con un precedente derecho de otro. La antitesis.

⁹ Que ella no es romana, ni en la formulación ni en los presupuestos, lo ha demostrado ampliamente DE FRANCISCI, *Il trasferimento della proprietà* (1924); cfr. más arriba, p. 41.

imponente si se piensa en los casos más característicos de las dos categorías (por ejemplo, en la tradición por una parte, en la ocupación de *ferae bestiae* por la otra) se vuelve mucho menos perceptible en algunos otros, en cierto modo limítrofes entre este y aquel grupo. Así, respecto de la adjudicación y de la *litis aestimatio* podría pensarse en una colocación entre los modos de adquisición a título derivado, porque en ambos casos, por efecto del proceso, se verifica un pasaje de la propiedad de uno a otro sujeto; pero es fácil ver que falta en una y otra hipótesis aquella coordinación entre el derecho del precedente titular y el del nuevo, que es esencial al concepto de adquisición a título derivado. Sobre la usucapión se ha discutido largamente, colocándola unos entre los modos de adquisición a título derivado, otros entre los a título originario: falta ciertamente también aquí la perfecta coordinación de que se ha hablado; pero sin embargo, en muchos casos, como veremos, se halla entre los presupuestos de la usucapión un acto técnicamente idóneo a la transmisión del dominio, o la voluntad que otro haya manifestado de transmitirlo. En consecuencia, consideramos oportuno tratar de la usucapión aparte, como de un modo de adquisición intermedio entre las dos categorías; en cuanto a la adjudicación, le conservamos el puesto tradicional entre los modos de adquisición a título originario, poniéndola al lado de la *litis aestimatio* que los tratadistas olvidan con frecuencia.

1) La ocupación y la adquisición del tesoro. — La ocupación es una adquisición de cosa que no está actualmente en propiedad de nadie (*res nullius*), mediante la toma de posesión. Caso típico es el de la caza y la pesca: la *fera bestia*, es decir, el animal salvaje (aun si, después de haber estado en propiedad de alguien, hubiera salido del lugar de su custodia sin una demostrable tendencia a retornar: *animus revertendi*), es de quien toma posesión de él; se discutía (cfr. D. 41, 1, 5 § 1) si bastaba para adquirir su propiedad el hecho de herirlo, seguido de actos demostrativos de la voluntad de apoderarse de él. El mismo tratamiento se da a los objetos inanimados que se pueden encontrar en el mar, sobre sus riberas, en los ríos públicos, como las conchillas, los fósiles, etc., objetos que sólo en el momento de la ocupación se hacen cosas en el sentido jurídico. Se consideran además como *res nullius* las cosas del enemigo ("maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent"; GAYO, IV, 16); en la edad histórica el botín propia-

mente dicho pertenecía al Estado, pero las cosas del enemigo que se encuentran entre los particulares pueden ser ocupadas por éstos, y por mucho tiempo el prisionero fué esclavo de quien lo tomaba.

Más controvertida es la naturaleza jurídica del acto de aprehensión con que se adquiere la propiedad sobre las *res derelictae*, es decir, las cosas voluntariamente abandonadas por el propietario. Parece que los sabinianos las considerasen *res nullius* y, en consecuencia, objeto de ocupación; mientras que los proculeyanos, admitiendo que el abandonante sólo perdía la propiedad de la cosa en el momento en que otro la recogía, tendían más bien a construir la relación como una *traditio in incertam personam*, semejante al *iactus missilium*, lanzamiento de monedas o de otros objetos que se solía hacer a la multitud en las fiestas públicas. Parece también que la doctrina sabiniana haya prevalecido, aun cuando los juristas no hubieran sabido librarse totalmente de la identificación con el *iactus*; pero para las *res Mancipi* abandonadas, en correlación con el principio de que no se admite la transmisión sino en los modos solemnes de la *mancipatio* y de la *in iure cessio*, se consideró que la ocupación debía ser integrada por la *usucapio*¹⁰.

Conceptualmente, otro aspecto de la misma institución es el régimen del *ager desertus*, tal como se halla regulado en dos tardías constituciones imperiales (C. 11, 59, 8 y 11). Si un propietario deja inculto su fundo, y después de una intimación pública de la autoridad local no vuelve a él dentro de los seis meses, cualquiera puede tomar posesión del terreno; y tal posesión se transforma en propiedad si dentro de los dos años el propietario no reivindica. Es, en sustancia, una expropiación; pero es característico que en la const. 11, la falta de presentación después de la intimación, es en cierto modo considerada como renuncia a la propiedad (*impares esse earum rerum tributis propria contententur*

¹⁰ A propósito cfr., en resuelta oposición, BONFANTE, *Scritti giur. vari*, II, ps. 327 y ss., y BERGER, *In tema di derelizione*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 32, ps. 131 y ss. La opinión aquí bosquejada importa una tentativa de mediación. En cuanto a la tesis de H. KRUEGER, *Derelictio und Usucapio*, en *Μνημόσυνα παππούλια*, Atenas, 1934, ps. 155 y ss. (retomada últimamente por KASER, "Rev. Fundac. Savigny", 65, 1947, ps. 221 y ss.), de que no obstante la pérdida inmediata de la propiedad por parte del abandonante también para las *res nec Mancipi* la adquisición de la propiedad por parte del ocupante se alcanzase sólo con la usucapión, no me parece ni impuesta por las fuentes, ni en sí misma probable.

absentia), y más todavía es característico que en textos bizantinos muy posteriores el régimen del abandono y el del *ager desertus* son considerados como una sola cosa¹¹.

Los principios de la ocupación rigen solamente en parte para el tesoro, definido (D. 41, 1, 31 § 1) como "*vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat*". La palabra *pecunia* debe entenderse aquí en un sentido lato, comprendiendo toda clase de objetos preciosos; en cuanto a la exigencia de que ya no se pueda establecer quién haya ocultado el tesoro, la razón está en el hecho de que de otra manera los herederos, aun indirectos, del que lo ocultó, serían los propietarios. A la aplicación del principio de la pertenencia del tesoro a quien de cualquier manera lo encuentre, que es lo único conforme a razón¹², obsta la concepción singular de la propiedad fundiaria romana, que se considera extendida a todo lo que contenga el fundo y el subsuelo; y obstan, además, las menos injustificadas razones del fisco, a quien pasaban, en Roma como entre nosotros, los bienes vacantes. Las diversas tendencias se conciliaron en un reglamento sugerido por el emperador Adriano, para quien el tesoro pertenece, normalmente, por mitad al descubridor y por mitad al propietario del fundo (que si se trata de suelo fiscal es el príncipe); a no ser que el tesoro haya sido encontrado como consecuencia de búsquedas no especialmente autorizadas por el propietario, o por él ordenadas, en cuyo caso el descubridor no tiene derecho a nada.

2) La *accesión*. — Se produce cuando dos cosas pertenecientes a distintos propietarios llegan a unirse de modo que constituyan una sola cosa. El principio es que el propietario de la cosa más importante (principal), o sea de aquella que mejor habría podido subsistir sola, continúa teniendo la cosa así acrecida. Así ocurre

¹¹ Cfr. ROTONDI, *Scritti giuridici*, III, ps. 45 y ss.

¹² En este sentido me adhiero plenamente a la tesis varias veces sostenida por PEROZZI (por último en "Riv. Dir. Comm.", 8, 1910. 1, ps. 253 y ss.) contra la institución del tesoro. No creo, en cambio, plausible la crítica que él hace de la definición romana citada (*Ist.*, 2ª ed., I, p. 690, n° 2; cfr. HUVELIN, *Furtum*, I, ps. 276 y ss.); técnicamente la definición dice todo lo que quiere decir y es, en consecuencia, inatacable. Ni siquiera existe la contradicción que PEROZZI cree señalar (p. 693, n° 3) entre la definición misma y D. 41, 2, 3 § 3: aquí se habla, probablemente por efecto de interpolación, de un tesoro impropio, recientemente ocultado por un dueño conocido (cfr. APPLETON, *Studi Bonfante*, III, ps. 1 y ss.).

en la *ferruminatio* (unión de dos trozos del mismo metal, por ejemplo, una estatua de bronce y el brazo correspondiente, a fuego y sin la intromisión de materia extraña)¹³; en la *scriptura* (accesión de la tinta al papiro o pergamino); en la *textura* (accesión de hebras del mismo o de otro hilado a un tejido). Mucho más discutido fué el caso de la *pictura*: a la controversia se refieren los dos textos referentes al tema, uno de GAYO (III, 78), el otro de PAULO (D. 6, 1, 23 § 3); y mientras PAULO resuelve la cuestión en el único sentido posible para quien contemple el problema desde el punto de vista materialista de la sustancia colorante que se adhiere a una tabla, es decir, en favor del propietario de ésta, la decisión de GAYO, que querría favorecer al pintor, crea desde el punto de vista técnico-procesal un verdadero desorden¹⁴: JUSTINIANO (I, 2, 1, 34) sigue servilmente a GAYO.

¹³ Distinto es el caso de la *plumbatura*, que se realiza colocando un cuerpo extraño entre las dos cosas que deben unirse. En este caso, parecería admitida la reivindicación, previo ejercicio de la *actio ad exhibendum*, con el fin de obtener la separación de la cosa accesoria (D. 6, 1, 23 § 5). Pero no está excluido que el texto haya sido retocado por los justinianeos (cfr. RABEL, *Grundzüge*, p. 442, n° 2).

¹⁴ Si el cuadro está en poder del antiguo dueño de la tabla, el pintor tiene la *rei vindicatio*; pero contra ella el ex dueño de la tabla puede oponer la excepción de dolo, con la cual consigue que el pintor le pague el precio de la tabla misma; no consiguiéndolo, conservaría la posesión del cuadro. Todo esto está en plena regla. Pero las cosas se complican si el cuadro se halla en poder del pintor. Sería natural que al ex dueño de la tabla se le concediese una acción de indemnización por el valor de la tabla misma; pero GAYO dice, en cambio: "si tu (pictor) possideas, consequens est, ut utilis mihi (domino tabulae) actio adversum te (pictorem) dari debeat; quo casu, nisi solvam impensam picturae, poteris me per exceptionem doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fueris". Acción útil (*utilis* = adaptada al caso especial, cfr. p. 146) y no ya *rei vindicatio*, es claro; pero es difícil suponer, por mucho esfuerzo que se haga, que sea una *actio in personam*. De cualquier manera, ella va dirigida no a una indemnización, sino a la restitución de la tabla, y contra ella el pintor no puede oponer sino aquella misma *exceptio doli* que en el caso inverso correspondía al *dominus tabulae* contra él; y así como aquél conservaba el cuadro si no se le pagaba el precio de la tabla, también lo conserva el pintor si no se le paga el precio de su obra. Parecerían, pues, colocadas ambas partes en idéntica situación, con el resultado de que cada una podía fácilmente quitar el cuadro a la otra. Tal vez quien ha escrito ha pensado que la preferencia le estaba asegurada al pintor por la desproporción entre el valor de la tabla y el de la obra; en el sentido de que, en suma, sólo el pintor podía estar dispuesto a indemnizar al otro. Sobre el tema, cfr. BORRULUCCI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 33, ps. 151 y ss., y *Scritti dedicati a C. Aron* (1928), ps. 14 y ss.; PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, p. 706, n° 1; BONFANTE, *Corso*, II, 2, p. 93; SOLAZZI, en el vol.

Mucho más consistente parece el principio que regula las accesiones de muebles a inmuebles: *superficies solo cedit*, es decir, todo lo que surge sobre el suelo pertenece al propietario de éste. Los casos típicos son los de la *satio* (siembra), *plantatio* (plantación), *inaedificatio* (construcción de un edificio); las atenuaciones que este principio ha sufrido con respecto al último caso las veremos en el cap. ix. También aquí es necesario que la cosa accesorio llegue a formar un solo cuerpo con la principal, y por eso no se adquiere por accesión la viga ajena agregada al edificio o a la viña; sin embargo, en las XII Tablas no se admite la reivindicación sino después que el edificio haya sido demolido o destruida la viña, y por lo menos para los edificios el principio permaneció en vigor hasta en el derecho justiniano. El propietario de la viga puede resarcirse mediante una acción penal *in duplum*, que parece ser una de las tantas adaptaciones de la *actio furti*.

3) A los *incrementos fluviales* se les aplican principios diversos según que los fundos ribereños sean *limitati*, es decir, tengan un límite también por la parte donde corre el río (o que el límite coincida con la orilla del río mismo cuando esté en crecida), o *arcifinii*, es decir, tengan en el propio río su límite. En el primer caso, el fundo no es susceptible de acrecimiento, y en consecuencia toda porción de suelo sustraída al río es *res nullius*, ocupable por cualquiera; en el segundo caso, el fundo se considera potencialmente extendido hasta la línea media del río, y en consecuencia susceptible de extensión si la superficie seca se amplía. Esto sucede por *aluvión*, es decir, por el insensible depósito de detritos; por *avulsión*, es decir, por la unión de una corteza del terreno que el río haya arrancado de un fundo superior y transportado contra el inferior (en este caso, sin embargo, el propietario precedente tiene derecho a reivindicar su parte de terreno mientras ella no haya formado cuerpo con el nuevo terreno, mediante la confusión de las raíces); por la emersión de una isla en el río (*insula in flumine*

Per il XIV cent. delle Pandette, Pavia, ps. 384 y ss.; NARDI, "Arch. Giur.", 121, 1939, ps. 95 y ss.

Cuanto hemos dicho demuestra cómo esta materia de la accesión fuese para los juristas más bien objeto de disputas escolásticas que de atención profunda; y lo mismo se puede decir para la especificación, la mezcla, etc., casos todos de escasa aplicación práctica, susceptibles como son de resolución amigable, sin intervención de tribunales y de jurisprudencia.

nata); por el abandono que el río haga de su lecho (*alveus derelictus*). En las dos últimas hipótesis, la media del río señala el límite de las partes de la isla o del lecho que corresponden a los ribereños de la derecha y a los de la izquierda: la división entre los varios propietarios de cada ribera tiene lugar "pro modo latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit" (D. 41, 1, 7 §§ 3 y 5); lo que parece debe entenderse en el sentido de una prolongación de las líneas de confín hasta la línea media o, si esto es imposible, por la oblicuidad del confín, en el sentido de la construcción de dos paralelas que partiendo de la extremidad de los confines hacia la media circunscriban el terreno que está frente al río (cfr. también fr. 29 h. t.: "veluti linea in directum per insulam transducta")¹⁵.

Pero en el caso de que emerja una isla anteriormente objeto de propiedad privada y después temporariamente sumergida, o que el río deje un lecho que se había formado recientemente a través de los fundos, el derecho justiniano considera que la propiedad precedente recobra su vigor (11, 7 § 5, 30 § 3 h. t.); se duda de la claridad de esta solución¹⁶. Se trataría de un descanso del derecho de propiedad, que reviviría íntegramente apenas eliminado el obstáculo natural.

4) La especificación es la actividad consistente en extraer de cierta materia o género una *nova species*, es decir, una cosa perteneciente a un tipo, o a un nuevo tipo; como si de una barra de oro se hace un anillo o de la lana un vestido o de la uva vino, etc. Entre los clásicos, los sabinianos consideraron que la cosa nueva pertenecía al propietario de la materia; los proculeyanos la atribuyeron al especificador; parecería, sin embargo, que los proculeyanos mismos distinguieran de los otros, ciertos casos, inherentes especialmente al tratamiento de los metales, en los cuales es po-

¹⁵ La opinión dominante, que ha pasado a los códigos modernos (hasta el art. 458 del Cód. Civ. it. de 1865), considera que las porciones deben fijarse trazando perpendiculares desde los puntos extremos de las líneas de confín sobre la media. Esto no me parece responder a la recta interpretación de los textos; además, es en ciertos casos impracticable, y en el caso de un río tortuoso trasformaría malamente la configuración de los fundos.

Disponiendo que los propietarios se dividan el lecho abandonado "según la extensión del frente de cada uno", el nuevo Cód. Civ. italiano de 1942 (art. 946) se adhiere a mi punto de vista.

¹⁶ RICCOBONO, *Studii in onore di F. Schupfer* (1898), 1. ps. 215 y ss.; GUARNERI-CITATI, "Annali Univ. Macerata", 1, 1927, ps. 107 y ss.; sobre la ley 30, § 3, BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 45, p. 450.

sible (por ejemplo, a través de la fusión) reducir la materia especificada al estado originario. Elaborando en este sentido un pasaje de PAULO en el cual la diversidad de las doctrinas estaba ampliamente desarrollada, los compiladores justinianos llegaron a la formulación general de una *media sententia*, según la cual la propiedad correspondería al propietario de la materia si la nueva especie pudiese ser reducida al estado primitivo, y al especificador en el caso opuesto. Ellos adoptaron esta tesis interpolando los pasajes en discusión y agregándoles la norma de la pertenencia al especificador toda vez que la materia fuese, en parte, suya¹⁷.

5) *Confusión y mezcla*. — Se verifica cuando varias cantidades susceptibles de mezcla (líquidos, mercaderías, etc.), pertenecientes a diversos propietarios, se funden en una sola masa. Por regla general, a la propiedad que cada uno tenía sobre su aporte se sustituye un derecho de condominio sobre la masa, por la fracción correspondiente en volumen o en valor; si diez medidas de mi grano se han mezclado con veinte o treinta de grano ajeno de la misma calidad, seré copropietario de la nueva hacina respectivamente por un tercio o por un cuarto; si una libra de oro mío se ha ligado con diez libras de bronce ajeno, de las once libras de liga seré copropietario, suponiendo entre los valores de las dos sustancias la relación de 1|500, por las 49|50 partes aproximadamente. Si la mezcla se hizo de acuerdo, o si no hay discusión sobre la originaria pertenencia de cada cantidad, la división puede solicitarse mediante la *actio communi dividundo*; de otra manera, cada uno debe reivindicar la cuota que le corresponde, pero puesto que por lo común el actor, ignorando la capacidad o el peso total, no conoce el denominador de la fracción que le pertenece, el pretor ha imaginado una fórmula especial con la que se reivindica "quantam partem paret ex illo acervo (o análogamente) actoris esse" (*vindicatio incertae partis*). También aquí, sin embargo, los juristas de la edad de los Severos (cfr. especialmente ULPIANO,

¹⁷ Como es claro, el desenvolvimiento descrito coincide, en buena parte, en cuanto a la valoración de la obra justiniana, con la tesis de PERROZZI ("Rend. Ist. Lomb.", 23, 1890, p. 177; cfr. *Istit.*, 2ª ed., I, ps. 686 y ss.); pero, aparte de que la *media sententia* me parece mucho más próxima de lo que piensa PERROZZI, a la opinión manifestada en el texto de PAULO en D. 41, I, 24 y 26 pr., considero muy probable la opinión de KASER ("Rev. Fundac. Savigny", 65, 1947, ps. 242 y ss.), que atribuye las opiniones allí afirmadas a los proculeyanos y que considera en general su tesis como la más conforme a los principios del derecho antiguo.

en D. 6, 1, 5 § 1) consideran distintos los casos en que "utraque materia etsi confusa manet tamen" (ejemplo, liga de bronce y oro) de aquellos en que la materia misma se consideraba, según las ideas del tiempo, como extinguida (ejemplo, la mezcla de vino y miel que se llamaba *mulsum*): en estos últimos casos se aplica el régimen de la especificación.

Una regla singular es la establecida en D. 46, 3, 78 (CASIO y JAVOLENO), para la mezcla de monedas ajenas con las propias: aquí la propiedad se pierde y subsisten solamente acciones personales, diversamente construídas según las relaciones entre las partes, para obtener la restitución de la suma.

6) La *adjudicación*. — Es, en la estructura jurídica, un caso inverso al precedente; en la confusión o mezcla la propiedad única sobre cierta cantidad se transforma en condominio sobre una cantidad mayor; aquí, en cambio, derechos de copropiedad se transforman en propiedad única. La adjudicación, en el sentido que aquí nos interesa, tiene lugar en los juicios divisorios, destinados precisamente a dividir las cosas o la herencia común entre los condóminos o los coherederos (*iud. communi dividundo, familiae erciscundae*), y es un pronunciamiento del juez dotado de eficacia constitutiva de derecho (*infra*, § 4).

7) *Litis aestimatio*. — También aquí un derecho de propiedad se adquiere a través del proceso; pero no en virtud de un pronunciamiento del juez, sino por la voluntad del demandado que se interpone entre el pronunciamiento y su realización. En el proceso clásico la condena no puede ser sino pecuniaria (p. 156) y, por lo tanto, cuando el juez haya declarado la pertenencia de la cosa litigiosa al actor (*pronunciatio iusti dominii*), no puede más que exhortar al demandado a fin de que voluntariamente restituya; si éste se niega, pronuncia la condena en dinero, y con el pago de la *summa condemnationis* el demandado adquiere la propiedad de la cosa¹⁸. Este modo de adquisición desaparece en el

¹⁸ Por lo menos para las *res nec mancipi*, la propiedad civil. Se enseña con frecuencia que la *l. ae.* hace adquirir en todo caso la simple *in bonis*. Pero entre los textos compilados por BETTI (*Studii sulla l. ae.*, I, Pavia, 1915, ps. 54 y ss.) los hay que afirman explícitamente la adquisición de la propiedad civil: cfr. especialmente D. 16, 3, 30 (*rem tuam fieri*); 6, 1, 46 (*dominium statim ad possessorem pertinet*); y el elegante cotejo trazado en D. 41, 4, 2, § 21. Si en D. 6, 2, 7, pr., § 1, se habla de *Publiciana* tanto en materia de *adiudicatio* como de *litis aestimatio*, debemos en ambos casos sobreentender el común presupuesto de un *iudicium quod imperio continetur* (cfr. más arriba, ps. 156 y ss., y 207). Y si en varios textos

derecho justinianeo, por el cual la *rei vindictio* conduce a la ejecución directa sobre la cosa controvertida (ps. 173 y 242).

8) *Adquisición de los frutos*. — Hasta que el fruto natural (cfr. p. 186) no se ha separado de la cosa fructífera, no tiene existencia autónoma en el mundo jurídico, y sólo puede ser objeto de contratación como cosa futura; apenas separado, se hace cosa y, en consecuencia, objeto de propiedad. Por el simple hecho de la separación, como quiera que suceda, se verifica la adquisición por parte del *dominus*, del titular de la propiedad provincial o pretoria, del titular de *ius in agro vectigali* o enfiteusis y —por derecho clásico— del poseedor que en el acto de la separación sea de buena fe¹⁹. En otros casos, el titular de un derecho (real o de crédito) que tenga por objeto la cosa fructífera, tiene facultad de adquirir sus frutos, pero es necesaria la percepción, es decir, la aprehensión material; están esencialmente equiparados, desde este punto de vista, el usufructuario, el locatario y el acreedor prendario (el último de los cuales tiene obligación de computar los frutos en los intereses que se le deben, o eventualmente en el capital); sin embargo, hay alguna diversidad en los límites en que la percepción está permitida, frente al propietario.

*
* *

Pasando a los modos de adquisición a título derivado, corresponde señalar la oposición profunda que existe entre el punto de vista romano y el de los ordenamientos actuales. Hoy no tenemos un sistema autónomo de los modos de transmisión de la propiedad:

(D. 41, 3, 27; 41, 4, 1) la *l. ae.* es considerada *iusta causa usucapionis*, esto se refiere quizá al ser la cosa *mancipi*, pero más probablemente a la hipótesis de que el actor no fuese el verdadero propietario (donde el demandado es, de cualquier modo, un adquirente *a non domino*). Entre los últimos tratadistas están por la propiedad civil, SIBER, ps. 99 y ss.; por la pretoria, KUNKEL, ps. 141 y ss. Tentativas de diversas soluciones, o de mediaciones entre las tesis extremas, en CARRELLI, *L'acquisto della proprietà per l. ae.*, Milano, 1934, y EHRHARDT, *Lit. aest.*, Monaco, 1934, ps. 156 y ss.

¹⁹ La regla del derecho justinianeo, por la cual el poseedor de buena fe demandado con la *rei vindictio* debe restituir los frutos no consumidos (*exstantes*, ver p. 242), es un caso de resolución de la adquisición ya verificada en el acto de la separación (cfr. BERTI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 34, p. 290).

los mismos contratos, que normalmente crean relaciones de deuda y de crédito, sirven también, llegado el caso, para transmitir la propiedad (cfr., por ejemplo, art. 1376, nuevo Cód. Civ. it.). Desde el momento en que el comprador y el vendedor se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio (o análogamente se ponen de acuerdo los dos permutantes, el donante y el donatario, etc.), la propiedad de la cosa se considera transmitida, aunque la entrega de la cosa misma y el pago del precio sean diferidos para un momento posterior; las formas de publicidad sancionadas para la propiedad inmobiliaria sólo contemplan la eficacia de la transmisión respecto de terceros. En consecuencia, podemos decir con absoluta exactitud, que una cosa es nuestra porque la hemos comprado.

En cambio, para el derecho romano, y no sólo para el derecho clásico sino (por lo menos formalmente) también para el justiniano, tal expresión sería inexacta. El contrato es siempre y solamente fuente de obligación, es decir, obliga a uno o a otro o a ambos contratantes a dar, hacer o no hacer algo respecto del otro; y como el mutuario contrae la obligación de restituir al vencimiento la suma que se le ha prestado, también el vendedor y el comprador contraen la obligación de transmitirse reciprocamente (dentro de los límites que oportunamente veremos) la posesión de la cosa y la propiedad de las monedas. Para que el comprador pueda decirse propietario, el vendedor debe cumplir, en ejecución de la obligación o de un pacto adjunto, un negocio especial, o bien es necesario que en virtud de un acto que transmita al comprador la posesión de buena fe trascorra el tiempo de la usucapión. Éste es el sentido de la máxima: "traditionibus (orig. mancipationibus?) ed usucapionibus, non nudis pactis dominia rerum transferuntur" (C. 2, 3, 20), que fué destinada a refirmar el principio cardinal del derecho romano contra las tendencias opuestas de las costumbres provinciales.

Los modos típicos de transmisión de la propiedad por actos entre vivos son, en derecho clásico, la *in iure cessio*, la *mancipatio*, la *traditio*: común la primera a toda categoría de cosas, propia la segunda de las *res Mancipi*, y la tercera de las *nec Mancipi*; en el derecho justiniano sólo la *traditio*. A estas tres instituciones se agrega el *legatum per vindicationem*, que si tiene por objeto una cosa corporal, es un verdadero modo de transmisión de la propiedad *mortis causa*; su lugar está en la materia de las sucesiones (cap.